

從〈洪範〉到憲法典^{*} —— 天命哲學的典範轉移

李念祖^{**}

目次

壹、題旨	五、庶民參與形成決策與審議 民主因子
貳、〈洪範〉大意	
參、〈洪範〉中的前憲政主義意識	肆、〈洪範〉未見的憲政主義構想
一、賦予正當性並言制裁的法 規範芻形	一、凡君王皆濫權的假設
二、以民本做為政治道德規範 價值命題	二、政治人格平等的假設
三、天子為民父母建其皇極而 彝倫攸序	三、定期選舉領袖的機制
四、王道無黨無偏與朋黨政治 無有比德	四、開明專制非權力分立
	伍、從〈洪範〉到憲法的典範轉移
	一、從天命到主權在民
	二、從等之到政治平等
	三、從道義到法治程序
	陸、結語

* 本文係為紀念吳大法官庚之先生而作，原曾刊登於《法制史研究》35期，頁 1-55，2019年6月。茲重新整理而略行增益，是為記。

[責任校對：莊佩芬、陳怡瑾]。

** 東吳大學法學院暨法律學系兼任教授。

穩定網址：<http://publication.ias.sinica.edu.tw/02510102.pdf>。



壹、題旨

憲法，為18世紀美利堅合眾國之發明；中文辭彙則是來自東瀛逡譯¹。設無日人此譯，使用中土文字還有其他一目瞭然之表達方式嗎？《尚書》²中有一篇文字，題曰〈洪範〉³。洪者，大也⁴，範者，法也、模也⁵，可兼從描述性的「範式」或規範性的「法則」解之。〈洪範〉就是大法⁶，其用語恰似與憲法慣稱為國家根本大法兩相吻合。然則〈洪範〉就是憲法嗎？〈洪範〉是在傳達引領憲政主義（constitutionalism）⁷的憲法（constitution）^{8、9}概念嗎？〈洪範〉與之旨趣有何異同？這就是本文的題旨所在。

- 1 其詳參見李念祖，「民之父母」與「始作俑者」之先秦儒家憲政思想端緒論稿，收於：吳庚教授七秩華誕祝壽論文集編輯委員會編，政治思潮與國家法學——吳庚教授七秩華誕祝壽論文集，頁74-76（2010年）。
- 2 《尚書》之名，首見《史記》〈五帝本紀〉：「學者多稱五帝，尚矣。然尚書獨載堯以來；而百家言黃帝，其文不雅馴，薦紳先生難言之。」參見司馬遷，史記，2版，頁43（2010年）。關於《尚書》之源流、篇目、真偽、考據等介紹，參見李民、王健，尚書譯注，頁1-37（2000年）。
- 3 《史記》〈宋微子世家〉：「天乃錫禹鴻範九等常倫所序。」及《呂氏春秋》〈貴公〉：「凡主之立也，生於公。故鴻範曰：無偏無黨，王道蕩蕩。」〈君守〉：「鴻範曰：惟天陰騭下民」兩篇，均稱為「鴻範」。參見司馬遷（註2），頁542；朱永嘉、蕭木，新譯呂氏春秋（上冊），頁34（1995年）；朱永嘉、蕭木，新譯呂氏春秋（下冊），頁947（1995年）。其鴻、洪兩字古通之故。
- 4 臺灣中華書局辭海編輯委員會，辭海，8版，頁2655（1996年）。
- 5 臺灣中華書局辭海編輯委員會（註4），頁3367。
- 6 程元敏，尚書周書——牧誓洪範金縢呂刑篇義證，頁27（2012年）。洪範之為大法，其法兼有範式、方法、模式、軌則、規矩之意，較今日所稱規範之意為廣。
- 7 亦稱立憲主義，「為世界各國的一個共同原理」，其介紹參見劉慶瑞，中華民國憲法要義，10版，頁1-4（1978年）。
- 8 關於憲法何以使用constitution一字之原委，馬漢寶教授曾為詳細之解說，參見馬漢寶，龐德論中華民國憲法之發展，憲政時代，3卷3期，頁29-30（1978年）。
- 9 按有憲政主義文化，未必有成文憲法典者，自大憲章以降之英格蘭是也。而有成文憲法典，其為憲政主義文化之結晶，猶更繼續積累成就深邃之憲政文化者，自獨立宣言出之美利堅合眾國是也；有成文憲法，始有憲政主義文化之積累養成者，則英美以外之舉世諸國也。若有不能成就憲政主義之憲法，非本文所稱之憲法。

按〈洪範〉為《尚書》諸篇之一¹⁰，記載殷周交替之際之事¹¹，學者久疑其非當時文獻，推考其成篇約在戰國時期¹²。本文則重在思想觀念之討論，不在精確年代之訓詁，既係「戰國初年儒者據故書或傳記做成」¹³，足以反映殷周之間的政治觀念乃至思想文化，即使非在周初時期做成¹⁴，甚或是否足以證實其記載之事蹟果然存在¹⁵猶可討論，亦於本文研究政治思想與政治文化之主題無礙。

10 四庫全書總目《尚書正義》二十卷，〈洪範〉列為第十二篇，位於周書〈秦誓〉、〈牧誓〉、〈武成〉諸篇之後，參見楊家駱編，尚書注疏及補正，3版，頁1、7（1985年）。

11 〈洪範〉於《尚書》中究應編入〈商書〉或是〈周書〉，歷來學者非無歧見。程元敏（註6），頁27-29。今人則多編入〈周書〉。《史記》〈周本紀〉記載武王克商之後祭天的場景儀式：「尹佚筮祝曰：『殷之末孫季紂，殄廢先王明德，侮蔑神祇不祀，昏暴商邑百姓，其章顯聞于天上帝。』於是武王再拜稽首，曰：『膺更大命，革殷，受天明命。』武王又再拜稽首，乃出。」簡單的段落，既表達了其為革命行為的本質，也說出了天命移轉的原因與道理，還有武王接受天命的歷史論述。司馬遷（註2），頁70。

12 程元敏（註6），頁28-30；同說如于省吾，尚書新證，頁98-99（1985年）；屈萬里，尚書集釋，頁114-116（1983年）。

13 程元敏（註6），頁28-30。梁啟超指為最早提出〈洪範〉年代問題之學者劉節，則以為〈洪範〉係秦統一中國前戰國末年之作，參見劉節，洪範疏證，收於：顧頡剛編，古史辨（五），頁402-403（1987年）。

14 程元敏（註6），頁30。今之論者，亦非無以為〈洪範〉最初文本問世係始於西周初年者，如黃忠慎之從徐復觀先生之說，參見何銘鴻，王安石〈洪範傳〉之解經形式，收於：林慶彰、錢宗武、蔣秋華編，第二屆國際《尚書》學學術研討會論文集，頁223（2014年）。

15 將〈洪範〉看做歷史材料，首先會出現的問題是，其記載之事是否曾經發生？這還可能不只是相不相信經文記載箕子說的故事（如天以〈洪範〉畀禹）是否確有其事，而還有像是「箕子歸」與「王訪於箕子」，矛盾與否？或是箕子與武王之間是否真有其事？這一類的問題。然則即使不信其中敘述的任何事蹟為真，也不影響〈洪範〉仍係書寫並反映作者（不論為誰）所身處那個時代（秦前）的一種史料，一種藉著傳說中甚或是創造出來的歷史故事，其背後所依存或構建的政治思想，顯然足以使得當時之人深信不疑以致影響其政治行為的歷史材料。

貳、〈洪範〉大意

《尚書》，儒學五經之中亦稱書經，依其內容乃記載上古夏商周三代重要政事而反映其間政治思想的史料集合¹⁶；也曾是後代歷朝君王經筵講習¹⁷的教本¹⁸，此在〈洪範〉一篇性質尤其明顯。其書序開篇言洪範之歷史背景：「武王勝殷殺受，立武庚，以箕子歸，作〈洪範〉。¹⁹」敘事邏輯係在敷陳武王克殷之後，從到來的箕子處紀錄了〈洪範〉的要義。此序應係有意顯示：紂子武庚稱臣受封而周武王獲得天命的事蹟與意義；以便開展說明其得天下為何具有政治正當性，還有如何才能繼續維持其正當性的道理。

天授人以使命的天命觀，或非周人的發明，但傅斯年先生以為，「天命靡常」（即「天命無常論」）的觀念則是²⁰；其主要論據在於《尚書》之數篇周誥²¹為可信，而天命無常理論之提出主要應

16 顧頤剛以為，《尚書》諸編中可信為真蹟的不過十二、三篇，〈洪範〉、〈立政〉兩篇「文義明暢，與〈大誥〉、〈康誥〉等篇「文體相差甚遠，當是後世史官補作」。顧頤剛編，討論古史答劉胡二先生，收於：古史辨（一），頁126（1987年）。

17 論者有謂，經筵做為皇帝御前講習，是一種特殊的、對唐宋以來政治情勢具有深遠影響的教育制度與政治制度。陳恆嵩，魏校及其《尚書》經筵講義析論，收於：林慶彰、錢宗武編，首屆國際《尚書》學學術研討會論文集，頁187（2012年）。

18 明太祖朱元璋曾經規定，儒臣進講四書以《大學》為先；五經以《尚書》為先。陳恆嵩（註17），頁188。

19 程元敏（註6），頁27-28。大意是周武王伐紂得勝而紂亡，武王封紂子武庚，因箕子來歸而作洪範。朱熹對於此序是否為孔子所作有疑：「（江彞叟疇）問：『勝殷殺受』之文是如何？」曰：「看《史記》載紂赴火死，武王斬其首以懸于旌，恐未必如此。〈書序〉，某看來煞有疑。相傳都說道夫子作，未知如何。」黎靖德編，朱子語類，卷79，頁2040（1986年）。〈洪範〉若係戰國作品，其書序自非孔子手筆。而朱子此語則已顯示了其評價聖賢的政治道德標準。

20 此語出自《詩經》〈大雅·文王〉：「侯服于周，天命靡常。」傅斯年，性命古訓辨正，頁129-142、148-150（1985年）。陳榮捷採同說，WING-TSIT CHAN, A SOURCE BOOK IN CHINESE PHILOSOPHY 3 (1963)。

21 周誥諸篇，包括《尚書》〈大誥〉〈康誥〉〈酒誥〉〈梓材〉〈召誥〉〈洛誥〉〈多士〉〈無逸〉〈君奭〉〈多方〉〈立政〉〈顧命〉〈文侯之命〉等13篇。傅斯年，中國古代文學講義，頁82-84（2009年）。此在編《古史辨》之顧頤剛先生言之，

是來自周公的擘畫手筆²²。商代天命觀之宗教色彩濃厚，「巫」的盛行扮演了重要的中介角色²³，周初則「以人事為天命之基礎」，開啟「人道主義之黎明」之思想轉變²⁴；在余英時先生言之，此後即漸由先秦諸子以道為貫通人天的心學取代了巫師們的神學²⁵。此項影響了中國政治歷史以數千年計的天命哲學轉變過程，在〈洪範〉一篇，無論其成書年代為何，也已顯出端倪。

〈洪範〉的經文曰²⁶：

惟十有三祀，王訪于箕子。王乃言曰：「嗚呼！箕子。惟天陰騭下民，相協厥居，我不知其彝倫攸敘。」箕子乃言曰：「我聞在昔，鯀堙洪水，汨陳其五行。帝乃震怒，不畀『洪範』九疇，彝倫攸斁。鯀則殛死，禹乃嗣興。天乃錫禹『洪範』九疇，彝倫攸敘。」

此中透過箕子之言傳達的用意或暗示，應係指〈洪範〉乃是具象的天命傳授，近乎天賜的治國寶笈。善君如禹如武王者，才有資格得到天命而接受上天賜予的智慧知識與訣竅治國，不賢之人如鯀（或是紂）則沒有資格享有天命，不能得到上天的幫助領受天心智

看法亦屬接近。顧頡剛，論今文尚書著作時代書（1923年6月10日致胡適之書），收於：古史辨（一），頁201（1987年）。至於〈洪範〉，傅斯年先生以為，〈洪範〉「綜言天人系統，而以五行之觀念為領，如這樣的典範，在戰國時恐不少有」。傅斯年（註21），頁93（2009年）。

22 傅斯年（註21），頁129-140。

23 余英時，中國文化史通譯，頁7-9（2010年）。

24 傅斯年（註21），頁134、140-142。《禮記》〈表記〉：「子曰：『夏道尊命，事鬼敬神而遠之，近人而忠焉……。殷人尊神，率民以事神，先鬼而後禮，先罰而後賞，尊而不親，……。周人尊禮尚施，事鬼敬神而遠之，近人而忠焉，其賞罰用爵列，親而不尊。……。』」可資參考。

25 余英時（註23），頁8-9。

26 程元敏（註6），頁31-35。大意是武王問於箕子，如何才能順應天意庇護人民，以天之常道常則治理人民，助使人民生活安定和諧。箕子的答覆是，昔日禹之父鯀築隄以防洪水，因逆水性以致五行汨沒而秩序大亂，引起天帝震怒，拒以洪範九疇予鯀，以至世道大亂，其結果鯀遭天放逐而亡。禹則繼起治理，上天以洪範九疇賜禹，恢復了天下的常道秩序。

慧治國。至於箕子，雖是殷商皇裔，究竟是如何得到洪範九疇？箕子似乎未與商紂而逕自傳予周武王？則均未明文交代，似亦少有問津者。

洪範九疇，即「範疇」一語之原典，指的是關於治國而可以分為九類的重要認識或基本原理原則，也可說是九種基本政治知識的領域。經文隨即列出洪範九疇的綱目²⁷，繼而分陳九疇之要義。此九疇分別是：

一、五行²⁸。其經義是在指陳五行之理。五行，一說是指水火木金土，於天地之間構成萬物而可利用的五種基本元素²⁹，一說是指五氣流行，也就是說充盈於天地之間的五種物性氣味，其順應天理而運行的自然道理³⁰。經文首先傳達的是，治國者所應該了解、運用之自然物性發展變化的基本原理。此疇若與前文「汨陳其五行」相對照，當有「五行失序則失天命，乃為政之首要認識」之意。（物理環境的基本原理）

二、五事³¹。其經義係在指陳為政應當善盡自性，謹慎修行個人的五項天資（容儀、談吐、觀察、傾聽以及思考），即

27 其經文：「初一日五行，次二曰敬用五事，次三曰農用八政，次四曰協用五紀，次五曰建用皇極，次六曰乂用三德，次七曰明用稽疑，次八曰念用庶徵，次九曰嚮用五福，威用六極。」

28 其經文：「一、五行：一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土。水曰潤下，火曰炎上，木曰曲直，金曰從革，土爰稼穡。潤下作鹹，炎上作苦，曲直作酸，從革作辛，稼穡作甘。」

29 參見錢宗武、江灝譯注，尚書，頁251-252（1996年）。係引用《尚書大傳》：「水火者，百姓之所飲食也；金木者，百姓所興作也；土者，萬物之所資生，是為人用。」以解釋五行是五種為人利用的物資。

30 程元敏（註6），頁42。

31 其經文：「二、五事：一曰貌，二曰言，三曰視，四曰聽，五曰思。貌曰恭，言曰從，視曰明，聽曰聰，思曰睿。恭作肅，從作乂，明作哲，聰作謀，睿作聖。」

容儀講求恭敬莊重、談吐講求順應事理、觀察講求明白昭澈、聽聞講求聰敏廣遠、思考講求通達無礙，以達於態度嚴整、言合條理、察察能知、善於策畫，而且睿智聖明的境界³²。(領導者修身的順序)

三、八政³³。其經義係在指陳無可闕少的八項施政要端，就是分設糧食、財貨、祭祀、居民、教民、治安、朝覲與軍旅八個部門，皆厚植其力³⁴。(不可或缺的施政要項)

四、五紀³⁵。其經義係在指陳應知天文曆法，瞭解歲紀月日星辰共同運行的天時曆數，按節氣以授民時的道理³⁶。(曆法曆數的基本知識)

五、皇極³⁷，此疇旨在用建皇極，就是由君王建立並施行政治秩序的最高準則之意。此前各疇，是描述君王所應通曉的統治環境與任務；此後各疇，則是認識君王處理政務的方法。此疇居九疇之中，用字最多，又以建立皇極為其內容，也就是樹立君權的法則，「以為人君體天用極之

32 錢宗武、江灝譯注(註29)，頁254；李民、王健(註2)，頁219-221。

33 其經文：「三、八政：一曰食，二曰貨，三曰祀，四曰司空，五曰司徒，六曰司寇，七曰賓，八曰師。」

34 程元敏(註6)，頁53-55；錢宗武、江灝譯注(註29)，頁254-255。

35 其經文：「四、五紀：一曰歲，二曰月，三曰日，四曰星辰，五曰歷數。」

36 參見程元敏(註6)，頁55-56；李學勤編，尚書正義，頁306-307(1999年)。

37 其經文：「五、皇極：皇建其有極。斂時五福，用敷錫厥庶民。惟時厥庶民于汝極。錫汝保極：凡厥庶民，無有淫朋，人無有比德，惟皇作極。凡厥庶民，有猷有為有守，汝則念之。不協于極，不罹于咎，皇則受之。而康而色，曰：『予攸好德。』汝則錫之福。時人斯其惟皇之極。無虐瑯獨而畏高明，人之有能有為，使羞其行，而邦其昌。凡厥正人，既富方穀，汝弗能使有好于而家，時人斯其辜。于其無好德，汝雖錫之福，其作汝用咎。無偏無陂，遵王之義；無有作好，遵王之道；無有作惡，遵王之路。無偏無黨，王道蕩蕩；無黨無偏，王道平平；無反無側，王道正直。會其有極，歸其有極。曰：皇極之數言，是彝是訓，于帝其訓，凡厥庶民，極之數言，是訓是行，以近天子之光。曰：天子作民父母，以為天下王。」

意」³⁸，允為〈洪範〉全篇篇旨之所在³⁹。於此列出其經文大意，係在指陳君主是建立政治秩序的終極標準。施政能聚集資源實現庶民的福祉，庶民則將遵行擁護君主的法則。不容官民結黨營私，惟君命是遵。應常思起用賢良；未犯大惡者應加寬容；態度和順而願意行德的人則予賜福；人們就會唯王令是從，不欺負弱勢而敬畏高明。使得有能力作為的人有所貢獻，政治就會昌明。不使有爵祿者有所貢獻，將會是罪過。而賜福無意行德的人，終會陷於過咎。臣民不容不平而行偏，要求遵行王令；不容循私，要求遵行王道；不容作惡，要求遵行正路。君王不偏私哪一群人，可彰顯為政坦蕩；不營結黨羽，可彰顯為政中道公平；不生反側，是因為為政正直。團結人心要得其法，要求遵奉君王的法則也要得其法。君王盡力推行這些法則，就順了天心。臣民也要盡力奉行上述的法則，以能接近天子的盛德光輝。天子要能作到像是臣民的父母一般，才有資格做天下的君主⁴⁰。(王權要領)

六、三德⁴¹，其經義是在指陳為政者治事御人的三種風範，一是真誠正直、一是剛強、一是柔和。對於中正平和的，真

38 程元敏(註6)，頁53、73。

39 朱熹形容為：「此是人君為治之心法」，黎靖德編(註19)，頁2041。

40 參見程元敏(註6)，頁53-73；李氏、王健(註2)，頁221-224；錢宗武、江灝譯注(註29)，頁256-258。

41 其經文：「六、三德：一曰正直，二曰剛克，三曰柔克。平康，正直；彊弗友，剛克；變友，柔克。沈潛，剛克；高明，柔克。惟辟作福，惟辟作威，惟辟玉食。臣無有作福、作威、玉食。臣之有作福、作威、玉食，其害于而家，凶于而國。人用側頗僻，民用僭忒。」三德，是君主治事治人所表現的三種不同風格風範，正直、剛強、柔和。德字作「行事作風」解，如《尚書》〈立政〉：「嗚呼，其在受德，賢為羞刑暴德之人。」參見錢宗武、江灝譯注(註29)，頁398。《論語》〈學而〉：「慎終追遠，民德歸厚矣。」〈顏淵〉「君子之德，風。小人之德，草。草，上之風，必偃。」參見錢穆，論語新解，頁15、438(1988年)。均屬此義。

誠正直以待；對於不肯馴伏或才不外露的，剛強以對；對於溫和順服或高超明智的，則柔和相待。惟有君主可以行賞行罰與食美饌，臣子則不可。臣子一旦行賞罰而食美饌，則將禍害邦家，招致官員們偏頗反側，庶民犯上作亂⁴²。（領導要訣）

七、稽疑⁴³，其經義是在指陳君主遇到重大疑難時，如何偵測吉凶而選擇決策的方向。基本上是依循占卜，並徵詢卿士及庶民意見的方法，循從多而決的方式決之⁴⁴。（解決疑難之道）

八、庶徵⁴⁵，其經義是在藉由五事、五紀之相與配合說理，指陳如何經常善察天象徵候以偵知君王政績良窳。不無促使君王定期經常省察施政得失的意思在內⁴⁶。（注意徵候以稽核得失）

42 參見程元敏（註6），頁74-86之討論；李氏、王健（註2），頁224-225。

43 其經文：「七、稽疑：擇建立卜筮人，乃命十筮。曰雨，曰霽，曰蒙，曰驛，曰克，曰貞，曰悔，凡七。卜五，佔用二，衍忒。立時人作卜筮，三人占，則從二人之言。汝則有大疑，謀及乃心，謀及卿士，謀及庶人，謀及卜筮。汝則從，龜從，筮從，卿士從，庶民從，是之謂大同。身其康彊，子孫其逢，汝則從，龜從，筮從，卿士逆，庶民逆，吉。卿士從，龜從，筮從，汝則逆，庶民逆，吉。庶民從，龜從，筮從，汝則逆，卿士逆，吉。汝則從，龜從，筮逆，卿士逆，庶民逆，作內吉，作外凶。龜筮共違于人，用靜吉，用作凶。」

44 參見程元敏（註6），頁36、39、87-100；李氏、王健（註2），頁225-227；屈萬里（註12），頁118。

45 其經文：「八、庶徵：曰雨，曰暘，曰燠，曰寒，曰風。曰時。五者來備，各以其敘，庶草蕃廡。一極備，凶；一極無，凶。曰休徵：曰肅，時雨若；曰乂，時暘若；曰晰，時燠若；曰謀，時寒若；曰聖，時風若。曰咎徵：曰狂，恆雨若；曰僭，恆暘若；曰豫，恆燠若；曰急，恆寒若；曰蒙，恆風若。曰王省惟歲，卿士惟月，師尹惟日。歲月日時無易，百穀用成，乂用明，俊民用章，家用平康。日月歲時既易，百穀用不成，乂用昏不明，俊民用微，家用不寧。庶民惟星，星有好風，星有好雨。日月之行，則有冬有夏。月之從星，則以風雨。」

46 參見程元敏（註6），頁116；李氏、王健（註2），頁227-229。

九、五福六極⁴⁷，其經義應係在提醒君主，不但崇尚天降五福即壽、富、康寧、攸好德、考終命以獎勸養人；也應當畏於天降六極即凶、短、折（三者均指短命），疾、憂、貧、惡、弱以為懲罰⁴⁸。此亦當有君應慮及其施政之善惡後果之義也。經文含蓄，實質上也在告誡君主，惡政後果嚴重，看起來卻像只在說常人的福禍壽夭而已。（明於福禍賞罰）

〈洪範〉，做為上天予禹的治國竅門，同時也是教誨與指導，這當然不是一部現代人理解的憲法。一個重要的差異是〈洪範〉源自天授（至少箕子或《尚書》上如此說），民主國家的憲法則是由人民的代表所通過，法理根源上顯然已不相侔。但是〈洪範〉的描述，也建構了君王所轄的政府與人民的某種關係，將其內容與政治哲學，與同樣是要規範政府與人民關係的憲法，乃至憲法背後的憲政主義思想對照，誠有價值進一步為比較研究。

參、〈洪範〉中的前憲政主義意識

依據憲政主義的假設，掌權的執政者是需要規範的對象⁴⁹。〈洪範〉以「範」稱名，其中有沒有、有多少規範意識或意義呢？有沒有、有多少憲政主義的假設或意識呢？是否可與憲政主義接榫？或可從五個角度分別討論。

47 其經文：「九、五福：一曰壽，二曰富，三曰康寧，四曰攸好德，五曰考終命。六極：一曰凶、短、折，二曰疾，三曰憂，四曰貧，五曰惡，六曰弱。」

48 參見程元敏（註6），頁40-41；屈萬里（註12），頁118。

49 劉慶瑞（註7），頁9。

一、賦予正當性並言制裁的法規範芻形

得天命是取得政治正當性的代名詞。但天命不與無行之惡人，君善是取得天命的前提條件，君之惡行會招致失位的後果。既有前提，也有制裁。

過去作者曾經就先秦儒家思想中憲政主義的脈絡是否存在、在什麼限度下存在，仔細進行探討⁵⁰。儒家思想自孔子作《春秋》以降，普遍存在為尊者諱、為親者諱的觀念⁵¹，現實政治環境是否容許責君之惡也非屬無疑⁵²；但在一定的限度上，仍曾出現過人君有惡的基本認知。子思回答魯穆公「何如而可謂忠臣」之間的時候，提出「恆稱其君之惡者，可謂忠臣矣」的答案⁵³，就是一例。不知是否受到子思影響，孟子在與梁惠王對話時，責備應當為民之父母的君主率獸食人⁵⁴，則是不假辭色而直指君惡另一個著名的例子。此中都已可辨識有意抑制君惡的憲政思想苗頭。

在這個問題上，〈洪範〉的記載揭示了更為根本的一個假設，一方面確與憲政主義抑制君惡的觀念交會，另一方面卻也足以解釋，兩者居然擦肩而過，其原因何在。這一個假設是存在於箕子的

50 李念祖，人國之禮——憲法變遷的跨越，頁9-186（2012年）。

51 《春秋》〈穀梁傳〉（成公9年）：「為尊者諱恥，為賢者諱過，為親者諱疾。」顧寶田注釋，新譯穀梁傳，2版，頁325（2016年）。論者亦有不以為然者，參見傅隽樸，春秋三傳比義（下冊），頁803-804（2006年）。

52 例如司馬作《史記》，以〈太史公自序〉列為最後一篇，有一段話：「上大夫壺遂曰：『昔孔子何為而作春秋哉？』太史公曰：『余聞董生曰：『周道衰廢，孔子為魯司寇，諸侯害之，大夫壅之。』孔子知言之不用，道之不行也，是非二百四十二年之中，以為天下儀表。貶天子，退諸侯，討大夫，以達王事而已矣。』」其中「貶天子」三字，當是史無前例的大膽用法；太史公既有意於孔子獲麟以後紹續往聖而當仁不讓，或亦暗示其作《史記》之志乎？既而用語含蓄，具見其身處於現實政治之難處。參見司馬遷（註2），頁1227-1228。

53 荊門市博物館，郭店楚墓竹簡，頁141（2005年）。

54 《孟子》〈梁惠王（上）〉：「庖有肥肉，廄有肥馬，民有饑色，野有餓莩，此率獸而食人也。獸相食，且人惡之。為民父母，行政不免於率獸而食人。惡在其為民父母也？仲尼曰：『始作俑者，其無後乎！』為其像人而用之也。如之何其使斯民饑而死也？」李學勤編，孟子注疏，頁16-17（2001年）。

話中；上天將〈洪範〉予禹予武王，而不予鯀，似乎也未予商紂，說明了上天有因材施教的選擇，其實也有鯀或紂根本不夠資格得到〈洪範〉這種君王教育的意思。一個可能的解釋是，洪範代表的是一種上天交付的道德使命，惟有德之君可以得之，似乎是極為自然的論述邏輯。簡言之，因為天命不予無德無行之惡人（如鯀）；得〈洪範〉之教就會像是得天命者的殊遇。惡君即使得位，天命也會轉移（如紂）；有德行之人始能有福，具備德行乃是獲得天命的前提條件。

細辨〈洪範〉中出現的君王，亦可知君王有善有惡，而命運（天命運轉的方向）不同。既有得天命的周武，也有失天命的商紂。紂王因惡行昭著而於牧野戰後敗亡⁵⁵；所謂天命無常，就像夏的天命曾經移轉至商湯⁵⁶一樣，商的天命也在〈洪範〉的記錄中移轉到了周武王的身上。〈洪範〉的記載可以用來證明，有惡行的君王是會失去天命的。更重要的是，得到或失去天命的原因，並非誰能以武力取勝，而是誰更具備聖君為民父母的道德資格或是潛能。天命，是因為德性的有無贏得民心，而不僅是跟隨武力而移轉的，這正是儒家向所言說，自堯舜禹湯文武周公以迄孔子所建立的道德傳統，及其間所繫的價值命題⁵⁷。

55 《尚書》〈牧誓〉：「今商王受惟婦言是用，昏棄厥肆祀弗答，昏棄厥遺王父母弟不迪，乃惟四方之多罪逋逃，是崇是長，是信是使，是以為大夫卿士。俾暴虐于百姓，以奸究于商邑。今予發惟恭行天之罰。」亦已顯示了周武伐商紂所使用奉天命而弔民伐罪的論述邏輯。錢宗武、江灝譯注（註29），頁239。

56 《尚書》〈湯誓〉：「有夏多罪，天命殛之。今爾有眾，汝曰：『我后不恤我眾，舍我穡事而割正夏？』予惟聞汝眾言，夏氏有罪，予畏上帝，不敢不正。今汝其曰：『夏罪其如台？』夏王率遏眾力，率割夏邑。有眾率怠弗協，曰：『時日曷喪？予及汝皆亡。』夏德若茲，今朕必往。爾尚輔予一人，致天之罰，予其大賚汝！」其論述邏輯，與〈牧誓〉相若。錢宗武、江灝譯注（註29），頁120。

57 《孟子》〈萬章（上）〉：「莫之為而為者，天也；莫之致而至者，命也。匹夫而有天下者，德必若舜、禹，而又有天子薦之者；故仲尼不有天下。」「孔子曰：『唐虞禪，夏后、殷、周繼，其義一也。』」李學勤編（註54），頁304-305。

此中所要處理的其實是憲政主義同所關切的問題：就是政府或是統治者的統治權威其正當性依據何在，是只經由武力取得大位的事實決定其正當性呢，還是另有標準？〈洪範〉所傳達的訊息是，以武力戰勝紂王而取得天下，只是已得天命的證據，但不是取得天命的原因或正當性理由。因君王有德行贏得民心而移轉的天命，才是主政者憑以取得政治正當性的根據⁵⁸。道德政治是直到清末民初，數千年間一再援用的政治文化觀念⁵⁹。

執政者的正當性要受道德檢驗，是天命哲學與憲政主義相同的地方，只是兩者用來檢驗的道德標準未必相同。天命哲學使用的一項檢驗標準是君王是否具有愛民如子的德行⁶⁰，憲政主義使用的檢驗標準，則是能否得到多數民意的支持獲選，還有政府是否符合憲法的要求，透過權力制衡的機制，以之為標準有效保障人民的基本權利。〈洪範〉背後的天命哲學，回答了周武王掌握大位的政治正

58 依陳榮捷先生的描述，周的創建者必須在推翻商的統治後為他們的統治提供正當性說明，乃從天命觀發展出以恆常可靠的德行所構成的自足道德規範體系。依其理論，人的命運，無論道德與否，不是取決於生命或死後的靈魂或是自然力量，而是取決於其本身的善言善行。周人因此認為，商人雖曾有天命，但因未盡其統治的責任而天命遭到沒收，天命移轉於周的創建者身上，是由於他們的德行使然。周室的未來，顯然也將取決於將來的統治者的德行。CHAN, *supra* note 20, at 3.

59 清末《宣統退位詔書》中有表示服膺立憲以成就共和國的段落：「因民軍起事，各省響應，九夏沸騰，生靈塗炭……以國體一日不決，故民生一日不安，今全國人民心理多傾向共和，南中各省既倡議於前，北方諸將亦主張於後，人心所向，天命可知。予亦何忍因一姓之尊榮，拂兆民之好惡，是……將統治權公諸全國，定為共和立憲國體，近慰海內厭亂望治之心，遠協古聖天下為公之義」，夏新華、胡旭晟整理，近代中國憲政歷程：史料薈萃，頁147-149（2004年）。其中「人心所向，天命可知」一句，用民心驗證天命歸趨，足資參照。論者有甚為肯定其憲法價值者，高全喜，立憲時刻——論〈清帝遜位詔書〉，頁82-85（2011年）。又依編者記載孫文先生於1924年回答俄國訪客的問題時稱：「中國有一個正統的道德思想，自堯、舜、禹、湯、文、武、周公至孔子而絕，我的思想，就是繼承這一個正統思想，來發揚光大的。」戴季陶，孫文主義之哲學的基礎，5版，頁43（1927年）。孫文先生其說的源頭，應是出自《孟子》〈萬章（上）〉：「孔子曰：『唐虞禪，夏后、殷、周繼，其義一也。』」。

60 〈中庸〉將「子庶民」列作「凡為天下國家有九經」之一，即為儒家重要經典講究愛民如子之一例，朱熹集注、陳成國標點，四書集注，頁34（2004年）。

當性問題，也建立了檢驗的標準。

有了檢驗標準，就有不合標準時如何制裁的問題。天命哲學與憲政主義的檢驗標準不同，但同樣要處理標準的效力問題。其不能通過檢驗標準的結局，則有高度相似之處，就是失位。天命哲學中的商紂像夏桀一樣，失位也失去了天下；憲法主義用憲法規定的選舉程序賦予執政正當性的執政者，如果施政成績不合檢驗標準，則會在下次選舉中失去民意支持而失位，如果是在位期間就被認定犯下違反檢驗標準（憲法）的錯誤，違憲的結果是政府行為無效⁶¹。無效，就是政府的行事不被認為具有政府的資格；不具備政府行為所可以發生的拘束力，其行事就要發生局部失位的後果。

政治正當性的檢驗標準具有制裁作用，是〈洪範〉所表現的天命哲學與憲法所彰顯的憲政主義，異曲同工之處。法規範的特徵是權威，對於所規範的對象具有權威，而且設有必須運用規範的機制，而且不能隨興地運作⁶²；簡言之，法規範告訴規範對象何者當為與不當為或是賦予權力⁶³；也就是賦予正當性與施加制裁。〈洪範〉傳達天命哲學中政治權力得喪變更的規則，權威感十足，使用「範」字用意明顯，天命規則至少具備了當代觀念中法規範的芻形。當然，〈洪範〉即使有意成為規範，其授與權力的作用，也遠較加施制裁的作用來得明顯。

從另一個角度看，〈洪範〉是儒家重要經典，影響深廣，今日天命說在海峽兩岸均是餘威猶在⁶⁴，但其敘述的時代與成書的年代

61 憲法第171條、第172條參照。

62 JOSEPH RAZ, THE AUTHORITY OF LAW 115-16 (1979).

63 *Id.* at 116.

64 孫文先生所言繼承中國的道德傳統，是20世紀初葉的例證。21世紀中，例如論者用「歷史和人民選擇了共產黨」來解釋中共領導中國的政治正當性問題（參見房寧，歷史和人民選擇了共產黨，中國青年報，2005年2月12日）。再如農曆春節政治領袖拜廟祈籤問運的舉動（參見林楠森，台灣來鴻：農曆新年的國運籤，BBC News 中文，2017年2月2日，<https://www.bbc.com/zhongwen/trad/>

均距今甚遠，從文義上研究其旨遠較研究政治實踐容易。然則〈洪範〉畢竟不是像制定首部成文憲法⁶⁵一樣的無中生有，即使是所依據的天命哲學，也應該是在前代即已存在⁶⁶，如果已經是一種具有廣泛影響力而足以左右政治實踐行為的思想習慣（如先王大禹之法），則〈洪範〉之性質應不失為習慣法⁶⁷的一段文字紀錄。其實

taiwan-letters-38841697（最後瀏覽日：2018年12月7日）；林保光，被問國運籤抽下下籤 蔡英文講這句話就離開，聯合新聞網，2018年2月6日，<http://blog.udn.com/Generalxen/110373516>（最後瀏覽日：2020年10月13日）。）做為稽疑占卜的一種形式，籤詩無論吉凶，一旦感覺靈驗，皆將益證天命之說不虛。此二例的背後都還有天命哲學的影子。

65 嚴格言之，世界上第一部成文憲法是由George Mason及James Madison共同草擬、北美洲的1776年維吉尼亞憲法（Virginia Constitution of 1776），亦是世人常推為首部成文憲法典的1789年美利堅合眾國聯邦憲法制定時的重要參考。維吉尼亞在成為美利堅合眾國最初的十三州之一之前，是參與獨立戰爭之十三國之一。（Virginia在加入聯邦之後被稱為州，其實只是翻譯文字的選擇，英文仍是維持一般稱之為國的state本字，此義從United States of America自始譯為美利堅合眾國，係以「眾國」譯States一字，亦可見之。）本文中所討論的許多基本而原則性的觀念，例如人的平等與權利（section 1, equality and rights of men）、權力來自人民（section 2, people the source of power）、為公共福祉而建立政府（section 3, government instituted for common benefit）、無食邑無特權無世襲（即階級平等）（section 4, no exclusive emoluments or privileges; offices not to be hereditary）、權力分立與定期選舉（section 5, separation of legislative, executive and judicial departments; periodical elections）、自由選舉與被治者的同意（section 6, free elections; consent of governed）、法律不教暫時停止（法治而非人治）（section 7, laws should not be suspended）均源自維吉尼亞憲法中的規定。See <https://law.lis.virginia.gov/constitution/> (last visited Oct. 13, 2020).

66 例如《尚書》〈西伯戡黎〉：「西伯既戡黎，祖伊恐，奔告于王。曰：『天子！天既訖我殷命。格人元龜，罔敢知吉。非先王不相我後人，惟王淫戲用自絕。故天棄我，不有康食。不虞天性，不迪率典。今我民罔弗欲喪，曰：『天曷不降威？』大命不摯，今王其如台？』王曰：『嗚呼！我生不有命在天？』」錢宗武、江灝譯注（註29），頁211-213。祖伊與商王之問答均係基於天命觀念，亦甚明白。

67 司法院釋字第419號解釋曾為憲政慣例下過定義：「憲政慣例在不成文憲法國家，恆居重要地位，其規範效力亦不容置疑。至於在成文憲法之下，雖亦有憲政慣例之概念，但僅具補充成文憲法之作用，尚不能與前者相提並論。所謂慣例係指反覆發生之慣行，其經歷長久時間仍受遵循，而被確信具有拘束行為之效力時，始屬不成文規範之一種。若雖有行為之先例，但因亦曾出現相反之先例或因有牴觸成文規範之嫌，拘束力備受質疑者，即不能認其為具備規範效力之慣例。」

世界上憲法發展的軌跡最早就是從憲政習慣（conventions of the constitution）（一稱「憲典」）轉變為憲法的過程，如果〈洪範〉揭露的是當時某種政治慣行實踐，例如八政的分工安排，也不令人意外⁶⁸。

二、以民本做為政治道德規範價值命題

許倬雲先生將周初的天命觀以八字形容：「天命靡常，惟德是親」⁶⁹。以仁德愛民，是周人自許自勵的施政風格⁷⁰，終究轉化為實質政治規範的內容，一種正當性的標記，也就是政治正當性的實質檢驗標準。於〈洪範〉之中描述的道理，就是「斂時五福，用敷錫厥庶民。惟時厥庶民于汝極。」「九、五福：一曰壽，二曰富，三曰康寧，四曰攸好德，五曰考終命。」天子與庶民同樣祈求的五

68 雷賓南即將conventions of the constitution譯為「憲典」。Albert V. Dicey著，雷賓南譯，英憲精義，頁509（1991年）。論者有以為〈洪範〉稽疑一疇不無可能是在反映殷商時期的政治文化，商王亦在決策地位上受到某些限制者。易建平，部落聯盟與酋邦——民主、專制、國家：起源問題比較研究，頁509-511（2004年）。

69 許倬雲，萬古江河——中國歷史文化的轉折與開展，頁57（2006年）；此語化自《詩經》〈大雅·文王〉：「侯服于周、天命靡常。」屈萬里，詩經詮釋，頁451（1983年）。《尚書》〈蔡仲之命〉：「皇天無親，惟德是輔。」錢宗武、江灝譯注（註29），頁381。關於周人天命的詳細描述，參見許倬雲，西周史，3版，頁95-106（1990年）。本質上這是武王及周公發展出來的理論，向天下之人，包括殷商遺民在內，解釋周替商的統治正當性在於德而來自天之命。〈洪範〉中提到天以洪範畀禹，實也不無法先王的用意在內。法先王，即效法上古三代聖王乃至周文王的治國風範，乃是理論上建立一套用以勸君教君的道德傳統，也就是用傳統先例中的優良政治慣行作為政治正當性的檢驗標準。傳統與天命，原是觀念上可加區分的正當性檢驗標準，然則專以先王的治國風範作為檢驗標準，有夏禮殷禮已不足徵的現實困難（《論語》〈八佾〉：「子曰：『夏禮，吾能言之，杞不足徵也；殷禮，吾能言之，宋不足徵也。文獻不足故也，足則吾能徵之矣。』」錢穆（註41），頁80。）將天命與道德傳統兩相結合，顯可相互補強政治上的說服力，其實是個替代的辦法。

70 如《尚書》〈召誥〉：「王敬作所，不可不敬德。我不可不監于有夏，亦不可不監于有殷。我不敢知曰，有夏服天命，惟有歷年；我不敢知曰，不其延。惟不敬厥德，乃早墜厥命。我不敢知曰，有殷受天命，惟有歷年；我不敢知曰，不其延。惟不敬厥德，乃早墜厥命。今王嗣受厥命，我亦惟茲二國命，嗣若功。」

項福祉，其內容就是長壽、富裕、康寧、活出道德的生命（攸好德，德行為其所好）、老時能得善終（考終命）。仁德之君踐行了為庶民謀五福的道德使命，上天當也同樣會報之以五福。

值得注意者，〈洪範〉在建皇極一疇中顯示君王所應致力的庶民福祉，概括籠統，而與余英時先生指出孟子曾「為國家（王）對人民的義務」開列過施行具體經濟政策的一張「義務清單」⁷¹相較，表達的方式並不相同。但〈洪範〉雖未指明君王應該為民追求的經濟福祉內容是些什麼，尚無損於〈洪範〉確有期待君王思以五福布施庶民的意思；同一疇中出現的「無虐鰥獨」四字，也很有些「瘵寡孤獨廢疾者皆有所養」⁷²的意味。五福（即壽、富、康寧、攸好德、考終命）是庶民的期盼原為古今常情，民之所欲常在君心而成為政策，君王應實現民意的意思已然呼之欲出。此外，建皇極一疇也說，君王為庶民謀福祉，庶民就會樂意追隨。當然，生命健康財富都由君王掌握，自是絕對的權力無疑。

對君王而言，此中自然也就有以民為本的道理。本也者，兼有根本、本旨、本源，可能還有政治資本的意思。「惟天陰鷲下民，相協厥居」，是說武王了解蔭庇人民和諧生活乃是上天的意志；「我不知其彝倫攸敘」，則是說：「我雖然已得天命，但不了解怎樣才能實現足以達到實現天心的人間秩序呢？」這顯示武王懂得，上天交

71 余英時先生認為這是中國版的權利清單，余英時，序，收於：朱敬一、李念祖合著，基本人權，頁14-15（2003年）。孟子答王問而提出的一張施政清單，見《孟子》〈梁惠王（上）〉：「不違農時，穀不可勝食也；數罟不入洿池，魚鼈不可勝食也；斧斤以時入山林，材木不可勝用也。穀與魚鼈不可勝食，材木不可勝用，是使民養生喪死無憾也。養生喪死無憾，王道之始也。五畝之宅，樹之以桑，五十者可以衣帛矣；雞豚狗彘之畜，無失其時，七十者可以食肉矣；百畝之田，勿奪其時，數口之家可以無飢矣；謹庠序之教，申之以孝悌之義，頒白者不負戴於道路矣。七十者衣帛食肉，黎民不飢不寒，然而不王者，未之有也。」李學勤編（註54），頁11-12。

72 語出《禮記》〈禮運〉：「故人不獨親其親，不獨子其子，使老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥、寡、孤、獨、廢疾者皆有所養。」孫希旦，禮記集解，頁582（1990年）。

付的任務（天命）就是護佑人民。人民，就是君王獲得天命的根本目的；就是君所以立的本旨；無民則無君，人民就是君職的本源；無須明言者，追隨君王的人民聚集眾多，甚至就是君王以廣招徠發揮其影響力、王天下的資本。所以《尚書》〈五子之歌〉會說：「皇祖有訓：民可近，不可下；民為邦本，本固邦寧」⁷³，人民做為邦國的根本，根本牢固，邦國自然安寧。〈洪範〉的說法則是：「天子作民父母，以為天下王」！

〈洪範〉闡明君王以人民福祉做為施政目的，就要懂得天地間物性運行發展的道理，自然天時運行的知識，環境災異的來去變化原因，厚施八政，照應人民的食糧、用品、祭祀信仰、居地、教育、治安、外交與禦敵的各種需求，才能實現人民的福祉。

政治道德規範的實質命題，當然也與政治正當性的問題息息相關，這在講究法治的憲政主義也是一樣。2018年唐獎法治獎得主、當代法實證主義巨擘Joseph Raz教授，得獎演說以「法的自有品性」（*The Law's Own Virtue*）為題，闡明憲政主義的法治，曾說⁷⁴：

政府係依據法律而設置，法律必然具有明示或默示的目的。在本質上，法律不能不有道德正當性的主張支撐，政府則應是法律適用與發展的憑藉。於解釋及適用法律時，身為政府必須顧及所以證立政府的目的。

政府若不計較其施政是否具備合目的性，就是武斷；任何政府追求依其本質不能稱為正當的目的，也是武斷。政府的施政必須像個政府！什麼才能使得政府像個政府呢？就是政府不能為了成就政府自身利益而存在；政府的正當性來自其施政須是為了被治者的福祉。

⁷³ 錢宗武、江灝譯注（註29），頁102。

⁷⁴ Joseph Raz, *The Law's Own Virtue*, 39 OXFORD J. LEGAL STUD. 1, 1-15 (2019).

法治作為法律的必要品性，要求政府施政必須彰顯只以保障及促進公共福祉（public good）為其目的。

品性（virtue，或是解為美德）一語，道德意味濃烈，或不下於〈洪範〉，其中道理也非無相通相合之處；〈洪範〉中愛民保民既然是上天交付天子的道德任務，當然具有實質道德規範的性質。然則將天命理解為上天交付的道德使命，憲政主義所說的法治核心要義，尚不在幾千年前〈洪範〉作者的思路之中，應無可爭。

三、天子為民父母建其皇極而彝倫攸序

〈洪範〉法天以垂諸後世的意味顯然⁷⁵。例如第七疇稽疑，從自然物事龜甲蓍草占卜以預示吉凶，第八疇庶徵，則從諸多自然徵候反映偵知執政績效，即甚明白。最直接的描述，就是第五疇首開先例，以「天子」稱君王，而將天與君以父子關係做為比擬⁷⁶。傅佩榮謂儒家的「天」原有多重意義，而〈洪範〉中的天，則「是天子政權合法性的基礎」⁷⁷。不僅如此，「不畀『洪範』九疇，彝倫攸斁。」「天乃錫禹『洪範』九疇，彝倫攸敘。」於是乎，載負天命天心的洪範九疇，所欲實現的終極目的，就是足以替代無秩序狀態的，人世間和順的群體倫理秩序。

75 程元敏以為「此疇演『次五曰建用皇極』，以明人君體天建極之義。」「上幅數著爾汝字，直稱武王也，亦所以謂後來君王也，蓋皇極者，非一家一世之書，先哲垂範明教，將以傳久遠也。」程元敏（註6），頁73。

76 亦有以為《尚書》〈立政〉中周公對成王說：「拜手稽首，告嗣天子王矣！」為初次出現天子之稱之處。杜勇，清華簡與古代探賾，頁106（2018年）。又《尚書》〈泰誓〉：「惟天地萬物父母，惟人萬物之靈，亶聰明作元后，元后作民父母。」錢宗武、江灝譯注（註29），頁222，是將天、君、人三者間的關係完整地以父母子女關係一再相與比擬的篇章。此則古文尚書疑為偽經之記載，按照內容言之，〈泰誓〉乃是牧野之戰的誓師之辭，時序恰應在〈洪範〉之前，而此篇未用天子而稱為元后（依甲骨書寫習慣，一字可以左右易換，后字疑與司字通），或係以為當時天命將降，猶未彰顯之故。更可見天子一詞之創意所在。又元后與元首兩詞義通，元后若即元司者，與總統一詞之用法亦接近，併此附記。

77 傅佩榮，先秦儒家哲學十六講，頁283-284（2018年）。

「建皇極」，皇者王也，極者，準則也。具體言之，〈洪範〉作者乃是運用自然血緣關係之中，夫婦父子所形成的人倫秩序，以君王為核心以期建立政治秩序。〈洪範〉本身即有建皇極，樹立最高之君主準則的意味，既有以之為天降的規範（至少是規範臣民）的意思，也是一種自然法⁷⁸。

按「天子作民父母，以為天下王。」這是將國君與人民的關係比擬為父母子女關係。不曰天子「為」民父母而曰「作」民父母，當亦有要求君王能夠像父母對待子女一樣地對待人民，才能作為天下真正共主的意思。孔子也曾經解釋，君王是要努力達到仁民愛物的一定境界，才有資格稱為民之父母⁷⁹，並非凡是君民關係就當然應該視作父母子女關係。

78 關於自然法之概念及相關討論，參見梅仲協，法學緒論，2版，頁20-35（1989年）。梅氏書中明言，「禮就是自然法」（頁76-77）。按君臣關係在五倫之內，統治關係與宗親血緣關係遂密不可分，此從「國家」一詞亦可看出。〈洪範〉並未直接使用「國家」之詞彙，但「害于而家，凶于而國」一語，庶幾近之；其又將不能脫離宗親血緣人倫觀念的君臣關係，置於自然宇宙運行框架的思考路徑明顯，所追求的乃是逆德禮法與宇宙秩序的和諧，在此意義上，即與自然法是從自然狀態中尋求人類行為之普遍應然的法則之逆德思路一致。參見Derk Bodde & Clarence Morris著，朱勇譯，中華帝國的法律，頁18-20、35-37、39-40（2008年）。論者討論儒家之禮是否就是自然法時，以為中國古代文化，禮法最終都歸根於自然，從中獲得形而上的根據，也依照自然而塑造其面目，「這個自然法與其說是禮，倒不如說是『天道』、『天理』。」「它們還是那些被認為是與天『意』，事實上是與宇宙結構相一致的東西」，與此可以互為印證。參見梁治平，尋求自然秩序中的和諧——中國傳統法律文化研究，頁385-386（2011年）。

79 如新出土之上海博物館《民之父母》楚竹書簡文中，顯示孔子回答子夏詢問君王成為民之父母的條件為何時，即曾如此說：「民之父母乎，必達於禮樂之源，以致五至，以行三無，以皇於天下。四方有敗，必先知之。其可謂民之父母矣。」（此與《禮記》〈孔子閒居〉還有《孔子家語》〈論禮〉中類同的記載，堪稱一致。）即已顯示民之父母絕不是無條件的君王頭銜。參見李念祖，「民之父母」與先秦儒家古典憲政思想初探——從上博楚竹書簡文談起，收於：人國之禮——憲法變遷的跨越，頁21-23（2012年）。惟世人言民之父母，常將之說成是身分關係而不是一種有條件的境界；與之相伴者，則是政府是父母官的觀念歷久不衰。

設如William Theodore de Bary所言可用社群主義比擬儒家者⁸⁰，〈洪範〉記載及顯示之儒家情懷，不啻係以天下為其範圍的社群主義⁸¹。〈洪範〉藉由自然法的論述方法，為以天下為範圍的宗族社群建立最高準則，就是以天子為中心，依人倫血緣及分封關係而存在的政治社會秩序。「民之父母」是訴諸人倫血緣，而農用八政的分工設爵，似已顯現（至少部分的）分封關係。

天賦人權的自然法思想與成文憲法背後的憲政主義，原具有千絲萬縷的關連⁸²。按照歐陸學者的通說，以人權為基調的憲法兼有建立客觀憲政秩序與保障主體基本權利之功能⁸³。〈洪範〉藉用法天敬祖的自然法論述，建立了訴諸天子為終極權威的客觀政治秩序，其實同時也具備憲法關於建立整體政治社會秩序的功能。

然則，憲政主義所講求的客觀秩序，是「自由民主之憲政秩序」。自由民主之憲政秩序所講求的核心法治觀念，原是要建立一種有限權力的政府（government of limited power），政府做為統治者也必須守法⁸⁴；而〈洪範〉為「彝倫攸斁」而建立皇極，則看不出多少有限政府的觀念。相反地，〈洪範〉雖然亦有稽疑、庶徵兩疇提醒君王審慎決策與不時自省以節制權力的作用，惟在建皇極一

80 de Bary特別強調儒家作為一種學術傳統，其所建立之特殊社群主義傳統，係存在於家、國及鄉之間者。WILLIAM THEODORE DE BARY, ASIAN VALUE AND HUMAN RIGHTS: A CONFUCIAN COMMUNITARIAN PERSPECTIVE 37-40 (1998).

81 《孟子》〈離婁（上）〉：「人有恆言，皆曰：『天下國家』。天下之本在國，國之本在家，家之本在身。」「為政不難，不得罪於巨室。巨室之所慕，一國慕之；一國之所慕，天下慕之；故沛然德教溢乎四海。」李學勤編（註54），頁228-229。其討論，參見DE BARY, *supra* note 80, at 34-36.

82 ALAN M. DERSHOWITZ, RIGHTS FROM WRONGS: A SECULAR THEORY OF THE ORIGINS OF RIGHTS 23-38 (2004).

83 吳庚，基本權的三重性質——兼論大法官關於基本權解釋理論體系，收於：司法院編，司法院大法官釋憲五十周年紀念論文集，頁7-22（1998年）。

84 我國憲法增修條文第5條規定，「政黨之目的或其行為，危中華民國之存在或自由民主之憲政秩序者為違憲。」政府必須守法的思想，在德國稱之為法治國原則（Rechtsstaat），與法治（the rule of law）有其相通之處。See BRIAN Z. TAMANAHA, ON THE RULE OF LAW-HISTORY, POLITICS, THEORY 92 (2004).

疇，不但無意限制王權，其促成王權集中之意，甚為明顯，至少有下列值得注意之處：

1. 「皇建其極」、「斂時五福」、「無有淫朋，人無有比德，惟皇作極。」這是由君王一人獨占政治終極準則的制訂權力。
2. 但凡是位善君，「天子作民之父母」，君王就居於人民父母的地位，庶民將視君為父母，君王也視庶民為子女。傅佩榮以為，父母子女原是人倫關係中唯一不可逆的關係⁸⁵，君民關係一旦等同於父母子女關係，就同樣不可逆反。
3. 父母子女是終身的關係，君民關係一旦等同於父母子女關係，就等同於終身不可逆反。終身是統治者，統治根基當然穩固，牢不可拔。
4. 天下惟有君一人是天子，即《尚書》〈湯誓〉中所稱之「予一人」也⁸⁶。〈洪範〉此疇顯已將世人區分為天子、人臣、庶民三等，而且諄諄告誡，只有君王可以施賞罰（作威作福），只有君王可以玉食；容許臣子作威作福就會亂政。這當然是為了集中王權於君王一人。
5. 「彝倫攸敘」，不但權力集中於君王一人，而且合乎天心天命之所託，具有政治正當性。

〈洪範〉所期待成就的這種客觀政治秩序，或許是反映當時以強有力政治秩序結束動亂的時代需要，也可能為天子所樂見，但並不是憲政主義法治理想中的正當憲政秩序。

85 傅佩榮（註77），頁402。

86 如《尚書》〈湯誓〉：「爾尚輔予一人，致天之罰，予其大賚汝！」錢宗武、江灝譯注（註29），頁121；又如《尚書》〈微子之命〉：「上帝時歆，下民祗協，庸建爾于上公，尹茲東夏。欽哉，往敷乃訓，慎乃服命，率由典常，以蕃王室。弘乃烈祖，律乃有民，永綏厥位，毗予一人。世世享德，萬邦作式，俾我有周無斁。」錢宗武、江灝譯注（註29），頁291，皆為其例。

四、王道無黨無偏與朋黨政治無有比德

〈洪範〉用了許多重覆性的語法說明君主應該行事公正，無偏無黨。也要要求人臣無有比德，無偏無陂，無有作好，無有作惡；庶民無有淫朋，惟皇作極。王道平平，是王道平坦且明於辨別而治理之意⁸⁷；淫朋，是聚眾僭越；比德，則是朋比之狀，或是政治影響力與君比肩⁸⁸。

此中所說的第一層道理，是臣民團結在君王之下，唯皇極是遵；以免各自呼朋結黨，反側分裂，破壞了彝倫攸敘。將朋黨看做一樁危險而且幾近有違政治倫理的事。

但此中還有另一層道理，就是臣民各結朋黨，政治上相互角力競爭乃至攻訐鬥爭，古今政治皆是習見而不易避免。今日的憲法之中尚有以「黨派」一詞加以描述之處⁸⁹。而當代之憲政國家皆行政黨政治，黨外有黨，黨內有派，少有例外。〈洪範〉以此為天子戒，當非憑空想像，多應係從實際政治經驗所累積的執政教訓而來。所不同者，〈洪憲〉似以朋黨政治為病態，教君以趨避處理之方；當代基於憲政主義運作的憲法，則不以政黨政治為病態，惟每設下政黨政治必須遵守而不可違抗之各種規則，以為控制⁹⁰。就此點而言，〈洪範〉較接近政治理想狀態的描述，而憲政主義則更像是承認政治現實的行為學派，致力設計因勢利導的制度安排。

87 平平，讀如便便，通說為治辨之意。其解可從《荀子》〈儒效〉得之：「分不亂於上，能不窮於下，治辨之極也。《詩》曰『平平左右，亦是率從』。是言上下之交不相亂也。」楊倞注、王先謙集解，荀子集解、考證，2版，頁112（2000年）。並參見郭建勳注譯，新譯尚書讀本，頁142（2011年）。

88 另一解則是不容人臣可與君王比肩的影響力。

89 我國憲法第7、80、139條皆其例證。

90 關於政黨，常見之憲法規則如：政黨平等、政黨為受憲法基本權保障之結社、政黨有遵守憲法不得危言自由民主憲政秩序之義務、政黨不得以武裝力量為政爭工具、法院須超出黨派以外獨立審判，不受政黨干涉等等，均可見於我國憲法第7、14、80、139條及憲法增修條文第5條各條之明文。

〈洪範〉與憲政主義憲法的共同點在於，二者同樣認為朋黨或政黨之相互攻軋，均不得有害於整體基本秩序之一統性或穩定性，此在〈洪範〉，乃是指必須遵奉天子所立皇極之彝倫攸斂；在憲政主義之憲法，則是不得否定自由民主之憲政秩序。

同時，當政者應當具有超越朋黨或政治黨派的公正態度，此在〈洪範〉，說的是天子的無偏無黨、無黨無偏；在憲政主義憲法，則或為元首對外代表國家之超然，或為司法之審判或其他機構（如監察、考試機關）行使職權之超出政黨政治之外⁹¹，或是行政機關之文官中立原則⁹²。凡此皆與維持整體基本秩序之一統性或穩定性直接相關。所不同者，憲政主義運用的是區分機關功能之制度安排，〈洪範〉則是將之繫於天子之治理智慧與政治手腕，只能是人治而不是法治。

簡言之，〈洪範〉看到了朋黨政治可能出現的政治現象，只是提供終身在位而身分固定的君王，維持超然中立與主動而不受脅制的基本建議，卻無意藉由細緻的制度安排，容許政黨政治發揮正面的功能。這一切當然是與〈洪範〉只是基於君王統治地位維穩的角度出發有關，憲政主義則是特別著重超越君主的立場，甚至是站在君主立場的對立面，只從整體制度的穩定著眼，設計防止政治進入不可收拾狀態的對策，方法及取徑（例如在政黨政治中兼顧權力分立與制衡，甚或將國家元首與內閣總理分設為不同的職位等）⁹³均

91 如憲法第80條：「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉。」

92 文官中立原則，論者解為政府一般文職人員政治中立，亦即事務官受政務官政策決定指揮，惟在個案決定上不因政治立場或黨派身分而使受不同之待遇而言。參見許濱松，英美公務員政治中立之研究——兼論我國公務員政治中立應有之作法，收於：彭錦鵬編，文官體制之比較研究，頁154-156（1996年）；李念祖，審判獨立、司法獨立、檢察獨立、檢察中立之憲法釋義辨，收於：司法者的憲法（二），頁425、427（2013年）。

93 內閣制或半總統制（或稱雙首長制國家）憲法，元首與總理分設不同之職位，與總統制異趣。我國亦將總統與行政院分設為不同之憲政機關，其功能區分詳

顯然有異。

五、庶民參與形成決策與審議民主因子

〈洪範〉第七疇稽疑之內容，是在提示君王為了偵知決策的吉凶而占卜，除應三占從二之外，君主遇重大難決之事，應與卿士及庶人討論，其規則是龜、筮、王、卿、民五中取三，即使王在少數，亦從多數決。其中有二例外，一是王從龜從而餘皆逆時，作內吉而作外凶；一是龜筮共違於人，用靜吉用作凶。二項例外中，前者外事從多數決，內事從少數決，或是因為尊重君王之故⁹⁴；後者龜筮在少數，人在多數，靜則從多數，動則從少數，一則顯示寧守不取，二則顯示從天似乎猶勝於從人⁹⁵。

於此乃有堪與憲政思想相較甚或接榫之處。按天子逢大事疑而不決，應依此疇慎謀而斷，亦不失為節制王權之一項途徑，與憲政主義規範並限制權力之意旨呼應，此其一者。

君主從龜從筮固係從乎天，從己從卿從庶民，則係從乎人。不寧惟是，此中業已納入了庶民，雖然君王與庶民全體的比重相當，而與選舉之票票等值⁹⁶不同，但仍不失為一種決策時應該徵取民意的思路，當是古代主張庶民實現參與形成政策的先聲。此其二者。

〈洪範〉或許不是〈尚書〉唯一重視民意的篇章。例如〈泰誓〉一篇中，即有「惟天惠民，惟辟奉天」、「天矜于民，民之所欲，天必從之」、「天視自我民視，天聽自我民聽」等等顯示民意重要的段落。但如此具體地建議君王重視庶民意見，其分量已達五分

見司法院釋字第627號解釋理由書。

94 論者即謂外事謂境外之事，「征伐事大，此非大吉故也。」參見程元敏（註6），頁96-100。

95 程元敏（註6），頁100。

96 例如憲法第129條規定，憲法規定之各種選舉，除憲法別有規定外，應依「平等」之方法行之。

而得其一，其亦前所未見者。

相對於《孟子》〈梁惠王（下）〉中所言：

國君進賢，如不得已，將使卑踰尊，疏踰戚，可不慎與？左右皆曰賢，未可也；諸大夫皆曰賢，未可也；國人皆曰賢，然後察之；見賢焉，然後用之。左右皆曰不可，勿聽；諸大夫皆曰不可，勿聽；國人皆曰不可，然後察之；見不可焉，然後去之。左右皆曰可殺，勿聽；諸大夫皆曰可殺，勿聽；國人皆曰可殺，然後察之；見可殺焉，然後殺之。故曰，國人殺之也。如此，然後可以為民父母⁹⁷。

若謂此與〈洪範〉第七疇相通而受其影響，或屬合理⁹⁸。當然，孟子強調身為民之父母的君王應重視民意，意思似更明顯一些。

〈洪範〉強調民意固與憲政主義之重視民主可相接軌，但畢竟不能同日而語。所不宜放過者則是民意觀念在天命哲學之中發生的特殊作用。天命哲學非自《尚書》〈周書〉始，〈虞夏書〉之〈皋堯謨〉：「天命有德，五服五章哉！天討有罪，五刑五用哉！」「勅天之命，惟時惟幾。」〈甘誓〉：「有扈氏威侮五行，怠棄三正，天用剿絕其命，今予惟恭行其罰。」〈商書〉中〈湯誓〉：「有夏多罪，

97 李學勤編（註54），頁62-63。此語之根據，當在《周禮》〈秋官司寇〉：「以三刺斷庶民獄訟之中：一曰訊群臣，二曰訊群吏，三曰訊萬民。聽民之所刺宥，以施上服、下服之刑。」鄭玄注、賈公彥疏、阮元等撰，周禮注疏及補正，頁7（2009年）。

98 〈洪範〉是聽取庶民意見以助君王遇疑難時做成決策，孟子則以為君王於用人用刑之際，就是該參考民意的場合。〈洪範〉透露民意重要之意似乎尤甚於孟子。惟孟子應無倡議輿論審判甚或庶民公審之意，蓋如殷海光先生所言，人民公審常是被宣傳和組織技術所形成者（殷海光，學術與思想（上冊），頁13-14（2010年）），實已涉及民主與司法審判理性有無衝突及界限的問題，尚有不宣。又《禮記》〈王制〉亦有：「刑人於市，與眾棄之。」孫希旦（註72），頁325。然此中庶民之參與方式，去〈洪範〉稽疑一疇所言較遠，亦甚明白。

天命殛之。」〈盤庚〉：「先王有服，恪遵天命。」「天其永我命于茲新邑」「無戲怠，懋建大命。」與〈西伯戡黎〉：「大命不摯，今王其如台？王曰：『嗚呼！我不有命在天？』」皆其例證⁹⁹。列於〈洪範〉之前的《尚書》其他篇章內容，亦不乏提及民意者，例如〈皋堯謨〉：「天聰明，自我民聰明；天明畏，自我民威。」及〈湯誓〉：「今汝其曰：『夏罪其如台？』夏王率遏眾力，率割夏邑。有眾率怠弗協，曰：『時日曷喪？予及汝皆亡。』夏德若茲，今朕必往。」皆是。惟皆莫如〈泰誓〉一篇中：

予小子夙夜祗懼，受命文考，類于上帝，宜于塚土，以爾有眾，底天之罰。天矜于民，民之所欲，天必從之¹⁰⁰。

將天命與民意結合，以為天命移轉的理論做為鋪墊者，其立論殆於此處為始，此種觀念正是將民意做為政權正當性來源之嚆矢！而〈洪範〉正式將民意支持納入君王決策程序之中，成為君王決策之正當性來源之一，不能不說已為數千年後，憲政主義將政府權力正當性基礎，從天命完全轉變成民意¹⁰¹，埋下伏筆。〈洪範〉有與

99 錢宗武、江灝譯注（註29），頁57、97、120、171、186、212-213。

100 〈泰誓〉中相關之完整論述如下：「惟天地萬物父母，惟人萬物之靈。亶聰明作元后，元后作民父母。今商王受，弗敬上天，降災下民。沈湎冒色，敢行暴虐，罪人以族，官人以世，惟宮室、台榭、陂池、侈服，以殘害于爾萬姓。焚炙忠良，剝剔孕婦。皇天震怒，命我文考，肅將天威，大勳未集。肆予小子發，以爾友邦冢君，觀政于商。惟受罔有悛心，乃夷居，弗事上帝神祇，遺厥先宗廟弗祀。犧牲粢盛，既于凶盜。乃曰：『吾有民有命！』罔懲其侮。天佑下民，作之君，作之師，惟其克相上帝，寵綏四方。有罪無罪，予曷敢有越厥志？同力，度德；同德，度義。受有臣億萬，惟億萬心；予有臣三千，惟一心。商罪貫盈，天命誅之。予弗順天，厥罪惟鈞。予小子夙夜祗懼，受命文考，類于上帝，宜于塚土，以爾有眾，底天之罰。天矜于民，民之所欲，天必從之。爾尚弼予一人，永清四海，時哉弗可失！」按〈泰誓〉作為周書為真為偽，聚訟固多，然「天佑下民，作之君，作之師，惟其克相上帝，寵綏四方。有罪無罪，予曷敢有越厥志？」曾見於《孟子》〈梁惠王（下）〉，近年出土之清華楚簡，有〈厚父〉一篇，內容類同孟子所引（參見如高佑仁，清華伍書類文獻研究，頁18-21（2018年））而無〈泰誓〉之其他內容，亦增〈泰誓〉之可疑。

101 以德意志基本法為例，其於1994年兩德統一之修憲序言中，猶言「凜於上帝與

憲政主義民主接榫之處，此其三者。

當代之憲政主義討論民主之正當性，常謂非僅在投票前之多數決而已，還在審議民主（deliberative democracy）之溝通討論以謀共識之精神¹⁰²。〈洪範〉之稽疑程序，聚政治菁英與平民之意見而冶於一爐，似亦不無審議民主的觀念因子存焉。此其四者。

有此四者，即不能謂〈洪範〉毫無憲政主義思想之端緒。18世紀法國路易十六的時代，有所謂三級會議（le tiers-etat）制度的概念，而法國大革命的導火線，就是對三級會議決議採用三院取其二制之不滿，亦即貴族院與教士院兩院同意加稅，平民院反對無用，竟釀成法國大革命。第三級會議要求按人頭而非順序投票，亦終形成法國制定成文憲法的呼聲¹⁰³；但若回到近三千年前商周交替的時刻，三占取二之說堪稱先進，其亦梁漱溟先生所以舉為人類文化早熟的一項例證之故¹⁰⁴。只是天命哲學歷時數千年而不變，早熟固然可貴，仍須有觀念之調整。

人民之付託」而終有通用於全體德意志人民的基本法，並未完全脫離天命觀之宗教色彩。參見國民大會秘書處資料組編，新編世界各國憲法大全（二）歐洲非洲國家，頁719（1996年）；朱建民原譯，陳沖、張桐銳增譯，德意志聯邦共和國基本法譯文，收於：司法院大法官書記處編，德國聯邦憲法法院裁判選輯（十五），頁337-394（2014年）。以1958年之法國第五共和憲法為例，其序言只在1789年之《人權及公民權宣言》與人權暨國家主權原則，已無任何宗教色彩，張台麟譯，法蘭西共和國憲法，收於：國民大學秘書處資料組編，新編世界各國憲法大全（第二冊 歐洲非洲國家），頁279（1996年）。以我國憲法為例，第48條規定國家元首之就職誓詞，雖然宣誓儀式似乎還是古代君王祭天的遺緒，其誓詞是：「余謹以至誠，向全國人民宣誓」，以及「如違誓言，願受國家嚴厲之制裁。謹誓。」民意取代了天心，也是褪盡了宗教色彩，已無任何天命哲學的影子。

¹⁰² 審議民主是為了克服以投票為中心的民主制度所形成的缺陷，而發展出來著重於公民社會如何進行公共審議程序的理論。其介紹見如WILL KYMLICKA, CONTEMPORARY POLITICAL THEORY: AN INTRODUCTION 290-94 (2d ed. 2001).

¹⁰³ SYLVIA NEELY, A CONCISE HISTORY OF THE FRENCH REVOLUTION 56-57 (2007).

¹⁰⁴ 梁漱溟，中國文化要義，頁265-266（1977年）。

肆、〈洪範〉未見的憲政主義構想

準此而為觀察，〈洪範〉所論述的君王治理制度模式，已然具備賦予政權正當性並帶有制裁的法規範權威芻形，以民本做為政治道德規範的實質價值命題，足以建立以天子為民父母的終極權威政治秩序，也已預見並設想避免朋黨政治威脅君王權威的因應之道，還有納入庶民參與形成政治決策的審議民主模式芻形，均與當代憲政主義不乏可以比較比擬的地方。然則，〈洪範〉畢竟不是憲法，也不等於憲政習慣的成文化書寫，在幾項關鍵環節上仍然欠缺成文憲法所以立基的若干憲政主義基本假設與構想，亦正何以中國傳統社會在遇到西方的憲政思想之前，不自具備生成憲政主義的文化土壤之故。以下分四個角度進行進一步的討論。

一、凡君王皆濫權的假設

在美國制憲會議之後所發表，相對於〈洪範〉而言，時代遠遠在後的美國重要制憲時期史料——聯邦論（*The Federalist Papers*）¹⁰⁵，在第51篇中，書寫著憲政主義對於政府權力的古典假設：

必須使用野心來對抗野心；必須使個人的利害關係與他所服務的那個部門的憲法權力發生關連；必須用這種方法來防範政府濫用權力，或許也只不過是在反映人類的本性而已。但是什麼是政府不也就是最大程度的人類本性反映嗎？如果人都是天使，就不會需要政府了。如果是由天使

¹⁰⁵ 此項經典著作，是由美國制憲時草擬憲法的三位要角，漢彌爾頓（Alexander Hamilton），麥迪遜（James Madison），及約翰杰（John Jay），以共同的筆名 *Publius*（建立羅馬共和的一位英雄人物）分別撰成85篇議論，在紐約的報端發表後集結而成，也是最早闡釋美國成文憲法要義的公共論述。參見錢永祥，權力與權利的辯證：《聯邦論》導讀，收於：謝淑斐譯，聯邦論 *The Federalist Papers*，頁IV-XIII（2000年）。

來管理人，對於政府的外部控制或內部控制都不必要。設計一個由人來管理人的政府，最困難之處在於，首先必須要使政府具有能力控制被統治者，下一步則是要使它做到自我控制。無疑地主要是要依賴人民控制政府，但人類從經驗中學到的是，還必須要有輔助性的預防措施¹⁰⁶。

一言以蔽之，憲政主義基於人類歷史上的政治經驗所做的基本假設是，執政者恆有濫權之惡。〈洪範〉之不同還不在能不能認識人君有惡。〈洪範〉中已有惡君商紂存在；其惡劣的程度，可於《尚書》〈泰誓〉見之¹⁰⁷。但是〈洪範〉與憲政主義左異之處，端在未曾假設掌權者必有濫用權力的危險；或許也有論述邏輯上難以假設得到道德天命的天子必然為惡的思考障礙。儒家之中與憲政主義假設最為接近的是子思之說：「恆稱其君之惡者，可謂忠臣

106 本段之原文是“Ambition must be made to counteract ambition. The interest of the man must be connected with the constitutional rights of the place. It may be a reflection on human nature, that such devices should be necessary to control the abuses of government. But what is government itself, but the greatest of all reflections on human nature? If men were angels, no government would be necessary. If angels were to govern men, neither external nor internal controls on government would be necessary. In framing a government which is to be administered by men over men, the great difficulty lies in this: you must first enable the government to control the governed; and in the next place oblige it to control itself. A dependence on the people is, no doubt, the primary control on the government; but experience has taught mankind the necessity of auxiliary precautions.” THE FEDERALIST No. 51, at 268 (James Madison).

107 《尚書》〈泰誓〉：「今商王受，弗敬上天，降災下民。沈湎冒色，敢行暴虐，罪人以族，官人以世，惟宮室、台榭、陂池、侈服，以殘害于爾萬姓。焚炙忠良，剝削孕婦。……吉人為善，惟日不足。凶人為不善，亦惟日不足。今商王受，力行無度，播棄黎老，暱比罪人。淫酗肆虐，臣下化之，朋家作仇，脅權相滅。無辜籲天，穢德彰聞。……惟受罪浮于桀。剝喪元良，賊虐諫輔。謂己有天命，謂敬不足行，謂祭無益，謂暴無傷。……今商王受，狎侮五常，荒怠弗敬。自絕于天，結怨于民。斫朝涉之脛，剖賢人之心，作威殺戮，毒痛四海。崇信奸回，放黜師保，屏棄典刑，囚奴正士，郊社不修，宗廟不享，作奇技淫巧以悅婦人。」錢宗武、江灝譯注（註29），頁222、227、229、233。商紂是否果真如此，對本文而言不是最重要的事，即使是出自後人的附會想像，亦可見得人們相信君主為惡可達此中描述的程度。

矣！」¹⁰⁸「君王恆有惡」之假設，呼之欲出。然則前引孟子責備君王率獸食人，還不忘記君王有民之父母的地位，與君為善的基本態度，實也不言可喻。《孟子》〈告子（下）〉中另一句名言：「長君之惡其罪小，逢君之惡其罪大」¹⁰⁹，更似有將君王之惡歸罪臣下之意。

至於〈洪範〉就距離更遠了。其中以為惡人不能得到天命的說法，其實導致了與憲政主義完全相反的假設。能夠得到天命的人，必是不會為惡的聖人¹¹⁰，接下來則假設其能成為民之父母。這不但難以解釋商紂王先前何以「有命在天」，也很難回答，好人在接位、甚至成為民之父母之後，若是發生濫權問題，有何有效對策？

根據前引典籍，孔子說到君王做為民之父母的時候，不止一次說明進入此一身分要有前提條件。《禮記》〈表記〉甚至顯示，孔子以為君王甚難做到民之父母的理想，「使民有父之尊，有母之親。如此而後可以為民父母矣！」¹¹¹憂憂乎其難，「非虞帝其孰能為此乎？」¹¹²固然是在勉勵後世君王以虞舜為師，實亦無異於一方面表達世人君王鮮有能稱為民之父母者¹¹²，另一方面卻也因是否達成

108 荊門市博物館（註53），頁141。

109 李學勤編（註54），頁393。

110 聖人的用語，古時就是君王的代稱。如《禮記》〈大傳〉：「聖人南面而治天下，必自人道始矣。」孫希旦（註72），頁905-906。

111 《禮記》〈表記〉：子言之：「君子之所謂仁者其難乎！《詩》云：『凱弟君子，民之父母。』凱以強教之；弟以說安之。樂而毋荒，有禮而親，威莊而安，孝慈而敬。使民有父之尊，有母之親。如此而後可以為民父母矣，非至德其孰能如此乎？主今父之親子也，親賢而下無能；母之親子也，賢則親之，無能則憐之。母，親而不尊；父，尊而不親。水之於民也，親而不尊；火，尊而不親。土之於民也，親而不尊；天，尊而不親。命之於民也，親而不尊；鬼，尊而不親。」¹¹²後世雖有作者，虞帝弗可及也已矣。君天下，生無私，死無厚其子；子民如父母，有憫恤之愛，有忠利之教；親而尊，安而敬，威而愛，富而有禮，惠而能散；其君子尊仁畏義，恥費輕實，忠而不犯，義而順，文而靜，寬而有辨。《甫刑》曰：『德威惟威，德明惟明。』非虞帝其孰能如此乎？」孫希旦（註72），頁1308-1309、1312。

112 《孟子》〈公孫丑（下）〉記載孟子說：「五百年必有王者興，其間必有名世

條件既無客觀標準也無認定機制，而難以防止他人任意恭維甚或聽任君王自稱民之父母。偏偏父母正是一種終身不可逆的人倫關係，自就更易助長君王的權力氣焰，若是發生君民關係比父母子女關係更重要，君恩大於父母恩的說法，也不令人意外。即使是出於與君出為善的好意，其中的矛盾並非淺顯。

類似的矛盾，即使在當代也會出現。例如今時憲法頗不乏限制國家元首連任限制次數者¹¹³，這不但是假設權力為惡，而且是在假設擔任元首掌握權力過了一定的期限之後，其濫權的危險已經使得他沒有資格再次擔任元首。但是，選民們投票時，莫不以為，至少是會假設，所選擇的是個適合擔任元首的好人（應該極少有人會明知是壞人還投票給他）。恐怕難以接受或是承認，投票支持的對象會濫用權力，或濫權危險已達不能再擔任元首的程度。這也正是為數眾多的忠實選民，所以不肯相信也不能接受，司法確定判決認定元首貪污否定自己當初投票判斷的心理原因。

孔子說民之父母的聖王難求，孟子說五百年必有王者興，實也反映了其所置身的現實政治環境中君惡充斥的臨場感。真正的矛盾，可說是出自政治理想與現實的矛盾，也是應然與實然的混淆與齟齬。好人始得天命，是政治的應然理想；商紂為虐，天命須要移

者。」〈盡心（下）〉中孟子又說：「由堯舜至於湯，五百有餘歲，若禹、皋陶，則見而知之；若湯，則聞而知之。由湯至於文王，五百有餘歲，若伊尹、萊朱則見而知之；若文王，則聞而知之。由文王至於孔子，五百有餘歲，若太公望、散宜生，則見而知之；若孔子，則聞而知之。由孔子而來至於今，百有餘歲，去聖人之世，若此其未遠也；近聖人之居，若此其甚也，然而無有乎爾，則亦無有乎爾。」李學勤編（註54），頁149、480-481。五百年始得一王者為民父母，遂知其難；而孟子無不豫之色，具見其樂觀。

113 例如我國憲法增修條文第2條：「總統、副總統之任期為四年，連選得連任一次，不適用憲法第四十七條之規定。」美國憲法增修條文第22條第1項規定：「No person shall be elected to the office of the President more than twice, and no person who has held the office of President, or acted as President, for more than two years of a term to which some other person was elected President shall be elected to the office of the President more than once.」（美國總統連選僅得連任一次。）

轉則是為了解釋政治現實。票投的是好人，是選民的政治理想希望，憲法的濫權假設，卻是中外歷史現實經驗幾無例外的教訓使然。虞帝，也不過是個美好的上古傳說而已。政治理想也許完全合乎理論邏輯，卻不能解釋其與政治現實所顯示的差距與矛盾。或許因為尚未參透此點，〈洪範〉才未出現憲政主義「掌權者恆將濫用權力為惡」的基本假設。

二、政治人格平等的假設

〈洪範〉寓含的民本論，其終極價值命題果然是民本嗎？可能是，也可能不是。「民為邦本，本固邦寧。」「本固」猶然不過是「邦寧」的手段；亦即「邦寧」的秩序和諧狀態，而非「民本」，才是民本思想追求的終極價值命題。就像是在主體權利保障與客觀憲政秩序之間，若將前者看後者的手段，終極目的將是憲政秩序而非權利保障；又若在我國憲法前言¹¹⁴中揭示的兩個憲法目的——「鞏固國權」與「保障民權」之間，將後者引為前者的手段¹¹⁵，終極目的就會是鞏固國權而非保障民權，意思相若。

民本做為獲致邦寧的手段，終極的價值即在維護君主的政權穩定，「彝倫攸敘」。為了彝倫攸敘，「惟辟作福，惟辟作威，惟辟玉食。」人臣尚不得玉食，而況庶民？此與君民之間不是處於政治上人格平等的位置，直接相關。天子與庶民既係處於不可逆的、終身不會改變的，和父母子女可相比擬的關係，政治上自無人格平等之可言。亦即天子的政治人格價值恆較任何庶民貴重，自己構成民本

114 我國憲法前言為：「中華民國國民大會受全體國民之付託，依據孫中山先生創立中華民國之遺教，為鞏固國權，保障民權，奠定社會安寧，增進人民福利，制定本憲法，頒行全國，永矢咸遵。」

115 我國憲法前言其實揭示了「鞏固國權，保障民權，奠定社會安寧，增進人民福利」共四項目標。如將「鞏固國權，保障民權」看成是一組，將「奠定社會安寧，增進人民福利」看成是一組，各自兩兩相比，以為位置在後才是最終的價值命題者，似乎都能得到，「民」而非「國」，才是憲法課與政府施政最後目標的結論。

與憲政主義民主之間的重大不同。

嚴復有云：「以貴治賤，故仁可以為民父母，而暴亦可以為豺狼。」用貴賤二字，已自掌握平等精神之肯綮¹¹⁶；其在討論英文 vote 一字，於傳統中文用語中並無直接相當的譯名，而只能取〈洪範〉之三占取二之占字表達多數決之意義時，對平等一事尤其言之甚切¹¹⁷：

宜乎古之無從眾也。蓋從眾之制行，必社會之平等，各守其畛畔，一民各具一民之資格價值而後可。古宗法之社會，不平等之社會也，不平等，故其決異議也。

即今中國，亦無用從眾之法以決策者，何則，社會貴者寡而賤者眾，既曰眾，則賤者儔也，烏足以成事？以是之故西方之福脫（vote）之字，於此土無譯，姑以占字當之，取占從二之義也。

而〈洪範〉之三占從二，原非在設計民主制度。反而是君主終身為君主，亦終身為民之父母，意即統治者終身為統治者，被統治者終身為被統治者，或統治者之附庸而已。乃無政治參與地位之平等可言；民本與民主自不能同日而語。而憲法上言投票地位之平等¹¹⁸，亦即「一人一票，票票等值」¹¹⁹，則是民主之精義。

116 孟德斯鳩著，嚴復譯，孟德斯鳩法意，頁257（2010年）。《左傳》〈昭公二十九年〉記載，晉鑄刑鼎，孔子不以為然，曰：「晉其亡乎，失其度矣，夫晉國將守唐叔之所受法度，以經緯其民，卿大夫以序守之，民是以能尊其貴，貴是以能守其業，貴賤不愆，所謂度也，文公是以作執秩之官，為被廬之法，以為盟主，今棄是度也，而為刑鼎，民在鼎矣，何以尊貴，貴何業之守，貴賤無序，何以為國？」左丘明著，竹添光鴻箋，左傳會箋（下冊），頁1745-1746（2005年）。貴賤無序，何以為國？道出了儒家崇禮而非刑鼎的疑慮。

117 Edward Jenks著，嚴復譯，社會通詮，頁164（2009年）。又嚴復譯《法意》之按語曾論平等：「夫民主之所以為民主者，以平等。故班丹（亦譯邊沁之言曰：人人得一，亦不過一。此平等之義也。」孟德斯鳩著，嚴復譯（註116），頁180。

118 我國憲法第129條：「本憲法所規定之各種選舉，除本憲法別有規定外，以普

儒家孔孟之主張，固非毫無平等之思想。如孔子之言「有教無類」¹²⁰，即與「非我族類，其心必異」¹²¹的不平等完全異趣。而《禮記》〈禮運〉篇中「老吾老以及人之老、幼吾幼以及人之幼」¹²²，尤為千古稱頌，以同理心言弱勢保障之至意，其亦人類文化之早熟思想之又一端。同理心，亦孔子之言恕道，「己所不欲，勿施於人」¹²³，實即平等觀念之源泉。

《孟子》上言「人皆可以為堯舜」¹²⁴，殆亦政治人格平等觀念之發端。惟君主聞孟子此語，其亦將以為「君皆可以為民之父母」乎？孟子因楊朱但為我，墨翟倡兼愛，而責以無親疏不分是君無父之禽獸¹²⁵，孔子則固言克己復禮為仁¹²⁶，然如《禮記》〈曲禮（上）〉：「夫禮者所以定親疏，決嫌疑，別同異，明是非也。」「君臣上下，父子兄弟，非禮不定」〈哀公問〉：「非禮無以辨君臣、上下、長幼之位也。」¹²⁷《荀子》〈王制〉：「先王惡其亂也，故制禮義

通、平等、直接及無記名投票之方法行之。」平等，為選舉投票之基本原則。

119 參見劉慶瑞（註7），頁101。此語其實正是嚴復說的：「一民各具一民之資格價值而後可。」「人人得一，亦不過一。此平等之義也。」

120 《論語·衛靈公》：「子曰：有教無類。」錢穆（註41），頁584。重在其平等。而「因材施教」，則視受教者之不同而施以不同的方法，重在其不同。

121 《左傳·成公四年》：「史佚之志有之，曰：『非我族類，其心必異。』」楚雖大，非吾族也，其肯字我乎？」左丘明著，竹添光鴻箋，左傳會箋（上冊），頁839-840（2005年）。

122 孫希旦（註72），頁582。

123 《論語》〈衛靈公〉：「子貢問曰：『有一言而可以終身行之者乎？』」子曰：『其恕乎！己所不欲，勿施於人。』」錢穆（註41），頁570。

124 《孟子》〈告子（下）〉：「曹交問曰：『人皆可以為堯舜，有諸？』」孟子曰：『然。』」李學勤編（註54），頁377。

125 《孟子》〈滕文公（下）〉：「聖王不作，諸侯放恣，處士橫議，楊朱、墨翟之言盈天下。天下之言，不歸楊，則歸墨。楊氏為我，是無君也；墨氏兼愛，是無父也。無父無君，是禽獸也。公明儀曰：『庖有肥肉，廄有肥馬，民有飢色，野有餓莩，此率獸而食人也。』」楊墨之道不息，孔子之道不著，是邪說誣民，充塞仁義也。仁義充塞，則率獸食人，人將相食。吾為此懼。」李學勤編（註54），頁210-211。

126 《論語》〈顏淵〉：「子曰：『克己復禮為仁。』」錢穆（註41），頁413。

127 孫希旦（註72），頁6、8、1258。

以分之，使有貧富貴賤之等。¹²⁸」皆所以說明禮為區別政治地位之政治制度架構，其恰亦與〈洪範〉以君臣民為天子、貴族、庶民三種階級區分的論述架構同源，遑論奴隸制度之長期存在¹²⁹。孟子說：「民為貴，社稷次之，君為輕」之言，固將從此一新世人耳目，終未改變〈洪範〉建其皇極而揭櫫了數千年政治階級不平等的格局¹³⁰。

〈洪範〉於開篇處即告訴讀者，商王受（即紂王）已經敗亡，治水有罪無功的鯀不能得到洪範九疇，為惡的人沒有資格享受上天賜命，即使是已在其位，天命也終會移轉。惡君因受天譴而被人民推翻，形成天命移轉的形勢，這是東方版本的暴君放伐論¹³¹。蕭高

¹²⁸ 楊倞注、王先謙集解（註87），頁132。

¹²⁹ 《周禮》〈秋官司寇〉：「其奴男子入于罪隸，女子入于舂蕘。凡有爵者，與七十者，未配者，皆不為奴。」鄭玄注、賈公彥疏、阮元等撰（註97），頁14。《漢書》〈衛青傳〉：「人奴之生，得無笞罵足矣，安得封侯事乎。」班固撰、顏師古注，漢書，頁631（1997年）。數千年奴隸制度，西漢王莽新朝初嘗更名奴婢曰「私屬」，「皆不得買賣。」惟不果（《漢書》，頁1043）。約兩千年後，清末沈家本以議立憲之故，請廢奴，而慈禧光緒許之。其係於光緒卅三年十二月上〈修訂法律大臣奏遵議滿漢通行刑律摺〉，提及此議，滿漢一體處理：「方今朝廷頒行憲法，疊奉諭旨，不啻三令五申，凡與憲法有密切關係者，尤不可不及時變通。買賣人口一事，久為西國所笑，律例內奴婢各條與買賣人口事實相同，此而不早圖禁革，與頒行憲法之旨，顯相違背。」詳參見徐世虹，沈家本全集，頁458-460、頁624-627（2010年）。並謂：「立憲之國，專以保護臣民權利為主。現行律中，以階級之間如品官制，使良賤奴僕區制最深，殊不知富貴貧賤品類不能強使齊，第同隸悒悒，權由天畀，於法律實不應有厚薄之殊」，「現在歐美各國均無買賣人口之事，係用尊重人格之主義，其法實可取。」詳參見李念祖，從陌生到顯赫——平等條款入憲史之談片，法制史研究，24期，頁273-274（2013年）。

¹³⁰ 《孟子》〈盡心（下）〉：「民為貴，社稷次之，君為輕。是故得乎丘民而為天子，得乎天子為諸侯，得乎諸侯為大夫。諸侯危社稷，則變置。犧牲既成，粢盛既潔，祭祀以時，然而旱乾水溢，則變置社稷。」李學勤編（註54），頁456。「是故得乎丘民而為天子」，似乎還是天子在上，本固邦寧的思路。又《孟子》〈滕文公〉：「無君子莫治野人；無野人莫養君子。」「或勞心，或勞力；勞心者治人，勞力者治於人；治於人者食人，治於人者食於人；天下之通義也。」李學勤編（註54），頁163、173。統治者與被統治者之區別似仍明顯。

¹³¹ 在西方，因宗教革命而出現臣民可否反抗軍人指為不守神聖法或自然法的君

彥研究指出，西方版的暴君放伐論，是源於馬基維利（Machiavelli, 1469-1527）的國家理性理論提出君王為惡的正當性，乃有以人民主權為基礎的暴君放伐論¹³²與之對抗。相較之下，〈洪範〉的暴君放伐論中，人民更像只是反映天命的介質，天命才是正當性的基礎所在。政治正當性基礎從天命完全轉向民心民意，就像西方一樣，還需要政治環境的營造機緣以及政治論述的醞釀時間。時機成熟時，制度發生的條件即足以影響制度內容。然則，直到18世紀，人生而平等，才成為肇興成文憲法典之美國獨立宣言所揭櫫之名言¹³³，也因此成為民主憲法典所奠基之民主制度的基本價值。憲政主義民主所不可缺少的政治平等，為〈洪範〉之中所未出現的假設¹³⁴，乃是事實。

三、定期選舉領袖的機制

〈洪範〉說紂王敗亡，為惡的人即使已在其位，天命也終會移轉。此處留下了一個疑問，人民除了嘗試革命，冒著成王敗寇的風險，拼個黃袍加身、天命轉移的機會之外，難道就沒有其他有效的辦法防止良君濫用權力變成惡君？

主之重大政治議題，是為暴君放伐論。參見蕭高彥，馬基維利主義、國家理性說與暴君放伐論：思想史的考察與政治哲學的反思，「吳庚教授逝世週年紀念」學術研討會，中央研究院法律學研究所、臺灣大學公共事務研究所主辦，頁10-13（2018年12月15日）。

¹³² 蕭高彥（註131），頁10-13。

¹³³ U.S. Declaration of Independence of July 4, 1776: "...We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal...that to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed." MERRILL D. PETERSON ED., THE PORTABLE THOMAS JEFFERSON, 235 (1977).

¹³⁴ 學者有以為古代中國亦非絕無天子與庶民平等之觀念者，蓋以新出土之清華簡〈厚父〉中有「惟時下民鴻帝之子，咸天之臣民」一句，是說天下萬民均為上天之子，在生命根源上，庶民與天子並無不同，天子不過是天之元子（長子）而已，觀點新穎。杜勇（註76），頁106。

〈洪範〉之中的辦法，似乎只有告訴天子，治理若不戒慎恐懼，失了民心就會失去天命，期許天子自覺自律，避免六極加身。簡單地說，除了靠天子自發從善，除了靠人民革命成功而天命移轉，尚少其他的制裁辦法。

其實連革命移轉天命的辦法，也有一理論邏輯上的問題懸而難決。君主是民之父母，革命是大逆不道之事，逼死君主使之去位，那是弑君。宋儒朱熹以《史記》記載的是紂王自焚而非遭武王所殺為由，對〈洪範〉序言「武王勝殷殺受」的「殺」字，懷疑此序的作者若是孔子怎會使用此字評價武王弑君¹³⁵，其故在此。紂王惡行昭彰，因周人革命而身死失位，孟子亦說是「聞誅一夫紂矣，未聞弑君」¹³⁶，皆所以開脫武王弑君的指責。

《史記》《儒林列傳》記載了轅固與黃生在漢景帝面前的爭辯¹³⁷：

黃生曰：「湯武非受命，乃弑也。」轅固生曰：「不然。夫桀紂虐亂，天下之心皆歸湯武，湯武與天下之心而誅桀紂，桀紂之民不為之使而歸湯武，湯武不得已而立，非受命為何？」黃生曰：「冠雖敝，必加於首；履雖新，必關於足。何者？上下之分也。今桀紂雖失道，然君上也；湯武雖聖，臣下也。夫主有失行，臣下不能正言匡過以尊天子，反因過而誅之，代立踐南面，非弑而何也？」轅固生曰：「必若所云，是高帝代秦即天子之位，非邪？」於是景帝曰：「食肉不食馬肝，不為不知味；言學者無言湯武受命，不為愚。」遂罷。是後學者莫敢明受命放殺者。

135 黎靖德編（註19），頁2040。

136 《孟子》〈梁惠王（下）〉，李學勤編（註54），頁64；《史記·殷本紀》：「帝辛，天下為之紂。」《諡法》曰：「殘義損善曰紂。」司馬遷（註2），頁62。

137 司馬遷（註2），頁1155。

太史公此項記載至少批判了兩件事，一是皇帝制止辯論，權力黨人。一是「遂不敢明受命放殺」的學者怯懦。太史公似在用此辯論顯示周初之後天命哲學理論無法解決現實問題的重大破綻：除了只能在革命成功的事後，告訴大家勝利者因為萬民擁戴而得到天命之外，沒有提出（不論是不敢想或者是沒想到）能在事前預防人君惡行的方法以為解決。看起來惡君會因革命而失位受到制裁，但這也還只是一種聽天由命的說法，不是制度化的制裁¹³⁸。

憲政主義的成文憲法則提供了使用民主選舉投票以產生政治領袖的程序機制，而且是要定期改選，來解決這個問題。定期改選，能使得施政不得人心的領袖定期失位，也預防了執政者因為終身在位而增加濫用權力的風險——「權力導致腐化絕對的權力，絕對導致腐化」¹³⁹。

定期改選，是一個和平的手段，使得武力革命失去了正當性，不但提供了事前預防的方法，也解決了革命是否弑君的理論兩難。

這個辦法改變了天命哲學的幾個前提：民意取代天命而成為政權正當性的主要或唯一依據、民主取代了民本的終極價值、平等取代了階級等差、定期改選取代了執政者的終身職位。

革命是具有高度政治風險的舉動，多會流血而使得無數人頭落地。而且真正到了非革命不可的時候，惡君的惡行亦常已使得無數

138 劉慶瑞（註7），頁9。張君勱先生說：「在君主制度下，此君主縱為聖君，然其一居君位，即能進而不能退。縱有聖人在下，永無為君之一日，則又能退不能進。然本於人之遵從主體對其自身之主宰性。則必要求使其自身活動之表現於政治上者，其進其退，皆同為可能，此中即有中國文化中之道德精神與君主制度之根本矛盾。而此矛盾，只有由肯定人人皆平等為政治的主體之民主憲政加以解決。」張君勱，新儒家思想史，頁644（1986年）。

139 “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” 此一名言出自英國歷史學家阿克頓爵士（Lord John Dalberg-Acton (1834-1902), letter to Bishop Mandell Creighton 3 April 1887). ANTONY JAY ED., OXFORD DICTIONARY OF POLITICAL QUOTATIONS 1(2d ed. 2005).

人頭落地。周初的天命哲學即使開啟了人道黎明，但是數千年不能解決政權如何和平移轉的問題，早熟也還需要轉變為大器晚成。

天命哲學重視祭天，原有君權神授的意味。只是「天」的神權色彩從「巫」轉化為「自然」之天之後，宗教的意味較為淡薄。而君權神授的殘餘影響，至今在世界上也還普遍可見。於其前言中明言國政之權威源於國民，以為「政治道德之法制乃具有普遍性」的日本國憲法，其第一章仍然規定天皇皇位世襲¹⁴⁰，天皇名稱原本具有天命神格的意味；英國的憲政傳統深厚¹⁴¹，天佑的女皇也是終身在位；美國用成文憲法取代了君王¹⁴²，其憲法前言雖然只以人民制定憲法做為正當性之來源¹⁴³，但是美國總統就職宣誓時，手按聖經發誓，帶有宗教色彩的天命意識依然意在言外；德國統一之後修改基本法的前言之中仍有上帝託付的字眼¹⁴⁴，均屬其例。但這些都是公認的民主國家，特別是終身在位做為國家象徵的元首，只為虛位之君的國度之中¹⁴⁵，幽微的君權神授意識，在一定的程度上與成文憲法所彰顯的定期改選機制，仍可並存，這就牽涉到下節討論的權力分立了。

140 謝瑞智譯，日本國憲法，收於：國民大學秘書處資料組編，新編世界各國憲法大全（第一冊 亞洲國家），頁217-218（1996年）。

141 謝瑞智譯，大不列顛與北愛爾蘭聯合王國（英國）憲法法典，收於：國民大學秘書處資料組編，新編世界各國憲法大全（第二冊 歐洲非洲國家），頁6-7（1996年）。

142 EDWARD S. CORWIN, THE "HIGHER LAW" BACKGROUND OF AMERICAN CONSTITUTIONAL LAW 1(10th ed. 1976).

143 "We the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America."

144 張台麟譯（註101），頁337-394。

145 例如英國的女皇，日本國的天皇是。

四、開明專制非權力分立

〈洪範〉所未出現的另一個憲政主義觀念，是權力分立。權力分立在今天已被大法官認為是成文憲法的一項修憲界限，不論憲法是否如此明文規定都無不同¹⁴⁶；即使動用修憲權力也不得使之不復存在於憲法之中，否則憲法也將不成其為憲法。此與世人迄今引為法治圭臬，於法國大革命時代、1789年8月26日制定之《人權及公民權宣言》第16條所定義的憲法：「不保證遵守法律保障權利的社會，不確立權力分立者，即無憲法之可言」，其理並無二致¹⁴⁷。

〈洪範〉缺乏權力分立的認識，不只在於是否假設執政者恆有為惡的危險而已，而是缺乏尋求程序機制以實現實體規範價值的思考習慣，對於如何預防執政者口是心非，或是確保執政者能夠力行實現其懸為目標的政治理想，未見設計具體的程序機制。前節所述使用定期改選來取代終身任職，就是憲法上一種防止濫權危險的程序辦法；權力分立則是〈洪範〉中所缺少的另一項程序性機制。〈洪範〉之中非但沒有權力分立的設計，而且是一種鼓勵君主集中權力以建樹統治權威的開明專制格局。

何以見得〈洪範〉提倡開明專制呢？從《論語》〈季氏〉中記載子曰「天下有道，則禮樂征伐自天子出；天下無道，則禮樂征伐自諸侯出。¹⁴⁸」之語或可參照。〈洪範〉中善治之君應建立皇極而專其賞罰，不正是禮樂征伐自天子出？孔子以之為天下有道；天子若不復以禮樂為天下準則（即不建皇極），再加之賞罰大權旁落於諸侯，則孔子稱之為天下無道。是無論〈洪範〉寫成於孔子之前之

146 參見司法院秘書處，司法院大法官釋字第499號解釋，收於：司法院大法官解釋續編（十三），頁685-699（2000年）。

147 Michel Troper, *Constitutional Law*, in INTRODUCTION TO FRENCH LAW 1, 2 (George A. Herman & Etienne Picard eds., 2008). 其所稱之權力分立，指依憲法規定而將權力分配給數個各擁權威的單位之意。

148 錢穆（註41），頁595。

後，皆可看出其間相與呼應契合的程度。一有孔子此段話語，〈洪範〉「斂時五福」四字掄揚開明專制之意不亦明顯？

按〈洪範〉次二農用八部，不是權力分立，也不是權力分立的芻形。農用八部是權力機關間分隔事務的分工，並不構成權力運作流程上的制衡。權力機關間的事務性分工，對於彼此工作的範圍互不干涉，只於分工界限不明確時發生爭取或是推諉的問題，不因彼此在功能上相互監督而形成節制權力的效果。八部雖有分工，但均隸屬於君主，受其指令指揮，向君主負責。明儒黃宗羲言簡而意賅，「是官者，分身之君也。」¹⁴⁹

權力分立制度¹⁵⁰中的立法、行政、司法三權分立，是一種水平的權力運作流程分工；一種先要形成抽象規範，再據之形成個案規範，必須經過審判確定後，才能對於個別人民發生實際上限制權利效果的規範流程。其中立法部門專司抽象規範制定，不負執行責任；行政部門則依法行政，負責執行抽象立法，制定細部規則，並針對個別人民形成個案規範（即發布行政命令或行政處分）；司法部門則是遇人請求時，依據法律裁判個案爭議的是非，包括審查行政部門的處分是否違法，才告形成直接拘束個人的個案規範（法院終局裁判）¹⁵¹。三權各自獨立，人員不相重疊，也互不隸屬¹⁵²，在功能上彼此節制牽制，但也因相互尊重而維繫長期平衡。

149 黃宗羲，明夷待訪錄，頁42（1986年）。

150 註105所引聯邦論第51篇的文字，也正是權力分立的制度理由。

151 美國聯邦最高法院曾如此解釋：“The functions of government under our system are apportioned. To the legislative department has been committed the duty of making laws, to the executive the duty of executing them, and to the judiciary the duty of interpreting and applying them in cases properly brought before the courts.” See *Commonwealth of Massachusetts v. Mellon*, 262 U.S. 447, 447-48 (1923).

152 此為美國成文憲法所設之制度，至於議會內閣制國家則行政部門內閣重要首長職位均由議會議員兼任，則是並不澈底之權力分立制度。

黃宗羲撰〈置相〉以為有明代之無善治，「自明太祖廢丞相始也」，說的是挑選賢相治國強勝賢肖仰賴天生的皇子皇孫¹⁵³，但區分君王與宰相的職位區分，與權力分立仍不能比擬。論者有云：「宰相之官，其性質，如從其史的發展上觀之，乃係君主之幕僚長，完全對君主負其責任」¹⁵⁴，一語道破宰相仍是專制君主之僚屬，與君主間之權力消長即使因時因人而異，如朱元璋之君強罷相是一極端，曹操司馬懿之相強逼君為另一極端，但都只是專制王朝上下之間的權力垂直分工，而與權力分立是平行的流程分工，具有抑制權力部門各守其分使不集中於一的功能，性質上大有不同。

權力分立制度本身，原不失為一種行使權力的正當程序（due process of law），正是憲政主義重視程序正義以實現實質正義的方法。〈洪範〉則較為重視實質價值，而未計較聖君也可為惡的概然性，也未思及利用程序價值以實現實質價值，更未考慮其中需要更多的方法設計，自然談不上在數千年前就能走上憲政主義之路。

也不妨這麼看，〈洪範〉強調治國之德（民本）與仁心（民之父母），進入了需要長時間醞釀、余英時先生所描述的，用問「道」的「心學」以替代尊「巫」的「神學」的思想突破過程¹⁵⁵，其間的基本方法，還是以尋思內求改善人心或君心的方法為主，而非取徑於發展或建構新的政治制度。此與周初的知識分子（孔子重視的士）尚待私學而非官學的教育，很難跳出職位的限制，從事突破性的超越，回頭批判和反思現實的政治世界¹⁵⁶，或許有直接的關係。早熟的思想，往往還是需要長期的試誤與咀嚼經驗教訓，才有

153 「古者不傳子而傳賢，其視天子之位，去留猶夫宰相也。其後天子傳子，宰相不傳子，天子之子不皆賢，尚賴宰相傳賢足相補救，則天子亦不失傳賢之意。宰相既罷，天子之子一不賢，更無與為賢者矣，不亦並傳子之意而失者乎？」黃宗羲（註149），頁42。

154 李俊，中國宰相制度，頁1（1989年）。

155 余英時（註23），頁6-8。

156 余英時（註23），頁9-10。

破繭而出的時刻。

從另一角度看，如果稽疑一疇的「審議民主」芻形有可能開展成為君王必須使用而不是想用才用的施政模式，也必須要有權力分立制度講究重視程序，審議式民主的立法與決策模式始有可能開展制度化的實驗與設計。其實，即使權力分立的制度已在今日施行，理想的審議式民主也只是一種想像與想望，距離普遍實現的境界，還相當遙遠。

再換個角度，憲政主義的權力分立之中，處於保障人權關鍵地位的司法審判，最是需要周延的程序設計，才能滿足其公正公平的需求。司法獨立，亦即由一個獨立的機關來審查檢驗並防止政府違法的程序機制，則是憲政主義權力分立制度之中不可缺少的法治要素¹⁵⁷。於此或應注意《尚書》〈立政〉之中周公對於成王¹⁵⁸的提醒，「庶獄庶慎，惟有司之牧夫是訓用違；庶獄庶慎，文王罔敢知于茲。」「立事。準人、牧夫，我其克灼知厥若，丕乃俾亂；相我愛民，和我庶獄庶慎，時則勿有閒之，自一話一言。我則未惟成德之彥，以乂我受民。」「繼自今文子文孫，孺子王矣！其勿誤于庶獄，惟有司之牧夫。」這三段話¹⁵⁹，可理解為勸誡君王慎獄慎刑，不率己意而為；同時就也有君王應以文王為典範，尊重司法獨立的意思（其中「文王罔敢知于茲」一句，是說文王不敢過問刑獄之事）。

古籍的記載，原也不乏君臣反覆聽審以求慎重的程序，例如《禮記》〈王制〉言施用刑罰的程序，從吏告於正、正告於大司寇，告於王，至三公卿士參聽，復告於王，王三宥然後制刑的程序¹⁶⁰；

157 法治斌、董保城，憲法新論，頁34-35（2003年）。

158 錢宗武、江灝譯注（註29），頁396。

159 錢宗武、江灝譯注（註29），頁400、402-403。

160 《禮記》〈王制〉：「成獄辭，史以獄成告於正，正聽之。正以獄成告于大司寇，大司寇聽之棘木之下。大司寇以獄之成告於王，王命三公參聽之。三公

到了清代的司法實踐還可約略見之¹⁶¹，固不謂不慎重。然其最終仍是由君王考慮是否法外施仁以為最後定奪，既無司法獨立之可言，程序上過度的反覆，某種程度上反而顯出程序不若實體目的重要；亦即其主要目的是在彰顯君王治國的慎重與仁德。與其說是為了庇蔭、保障被告，不如說是為了突顯君王的高度¹⁶²。此外宋代有審與判分別由不同的法曹辦理的制度¹⁶³，反倒是與權力分立的流程分工比較接近的辦法。但這類的想法均未在〈洪範〉中見之。〈洪範〉中只言賞罰之權應向君主集中，尊重司法獨立而慎刑慎罰的提醒，則似只在〈立政〉中曇花一現。

伍、從〈洪範〉到憲法的典範轉移

〈洪範〉的天命哲學所未見者大別有三端：君恆有惡的問題、憲政主義中民主的實質前提——政治平等，與憲政主義中包括權力分立、司法審查在內的民主程序節制權力機制。一旦施行憲政主義憲法，即生天命哲學走向憲政主義的典範轉移。以下分別論述之。

以獄之成告於王，王三又，然後制刑。」《禮記》〈文王世子〉：「公族其有死罪，則磬于甸人。其刑罪，則纖剕，亦告于甸人。公族無宮刑。獄成，有司讞於公。其死罪，則曰『某之罪在大辟』；其刑罪，則曰『某之罪在小辟』。公曰：『宥之。』有司又曰：『在辟。』公又曰：『宥之。』有司又曰：『在辟。』及三宥，不對，走出，致刑於于甸人。公又使人追之曰：『雖然，必赦之。』有司對曰：『無及也！』反命於公，公素服不舉，為之變，如其倫之喪。無服，親哭之。」孫希旦（註72），頁372、573。

161 以死刑案件為例，依學者以製表方式歸納，自州、縣偵查以至皇帝批示前，共經府、按察史司、總督或巡撫、刑部、三法司、經手凡七級，與古籍可相對照。參見Derk Bodde & Clarence Morris著，朱勇譯（註78），頁109-110。

162 以「惟天陰騭下民」一語言之，即是強調「惟天」甚於「陰騭下民」。（宋）蘇軾將「殺之三、宥之三」以刑賞忠厚之至為題為文，其意相若。

163 此制稱之為鞠讞分司，「是將審與判分開，由鞠司負責審（推鞠），由讞司負責判（檢法所刑）。」那思陸，中國審判制度史，頁166（2004年）。

一、從天命到主權在民

自〈洪範〉的時代進展到今時憲政主義之憲法典，其實經歷了長期的歷史發展¹⁶⁴。其過程尚不能於此細述，但是從其思想變化的脈絡仍可掌握若干重要的綫索，或可藉之思索日後研究其間過程的取徑方向。

〈洪範〉不僅暗示其內容是先王大禹之法，還表現了周初漸從「有命在天」到「天命靡常、惟德是親」之政治正當性理論的建構與變化過程剪影。從「有命在天」轉變到「天命靡常、惟德是親」，是在「天命」作為統治正當性的唯一標準之外，增加了「有德」一項新的標準。〈洪範〉中「民之父母為天下王」，稽疑時詢問庶民意見，遂又納入第三個衡量政治正當性的標準——民意。然而，三者之間，究竟是民意追隨有德者，還是有德才合乎民心？是天命隨民意移轉，還是人民應該服從天心的選擇？是天命隨著有德移轉，還是得天命者應該有德？都似有理，但答案並不清楚。

其實〈洪範〉的內容，也還未交代展現當時決定政治正當性的全部關鍵要素。例如天子傳位於子，新王即有天命者，究竟是天子的選擇原為天命移轉的根據，還是血緣才是天命依附的所在？此中的規則似乎是天子有選擇時依天子的意志，無意志時則須有血緣關係存在才成。

但問題尚非如此簡單，繼承與封建，如同上述黃宗羲所言子孫之中未必有賢德者，天子決定王位傳承，應該選擇賢者還是子孫呢？禹選擇了伯益，卻是禹之子啟得了王位，也就是天命，首開數千年間均成家天下的局面¹⁶⁵，如何解釋天子禹的意志不是指標？孟

164 李念祖，「民之父母」，「其無後乎」？——論先秦儒家古典憲政思想的進度與限度，收於：《人國之禮——憲法變遷的跨越》，頁157-166（2012年）。

165 《三字經》：「禹傳子，家天下。」《漢書》〈蓋寬饒傳〉：「五帝官天下，三王家天下，家以傳子，官以傳賢。」班固撰、顏師古注（註129），頁826。

子的回答是：「天與賢則與賢，天與子則與子。」¹⁶⁶」所以真正的決定因素是神秘的天心（或是繼位者取得政權的事實）。但孟子在舉例的時候又說：

昔者舜薦禹於天，十有七年，舜崩。三年之喪畢，禹避舜之子於陽城。天下之民從之，若堯崩之後，不從堯之子而從舜也。禹薦益於天，七年，禹崩。三年之喪畢，益避禹之子於箕山之陰。朝覲訟獄者不之益而之啟，曰：「吾君之子也。」謳歌者不謳歌益而謳歌啟，曰：「吾君之子也。」丹朱之不肖，舜之子亦不肖。舜之相堯，禹之相舜也，歷年多，施澤於民久。啟賢，能敬承繼禹之道。益之相禹也，歷年少，施澤於民未久。舜、禹、益相去久遠，其子之賢不肖，皆天也，非人之所能為也。莫之為而為者，天也；莫之致而至者，命也。匹夫而有天下者，德必若舜禹，而又有天子薦之者，故仲尼不有天下。繼世以有天下，天之所廢，必若桀紂者也，故益、伊尹、周公不有天下。伊尹相湯以王於天下。湯崩，太丁未立，外丙二年，仲壬四年。太甲顛覆湯之典刑，伊尹放之於桐。三年，太甲悔過，自怨自艾，於桐處仁遷義；三年，以聽伊尹之訓己也，復歸于亳。周公之不有天下，猶益之於夏，伊尹之於殷也。孔子曰：「唐虞禪，夏后、殷、周繼，其義一也」¹⁶⁷。

這一段話中的政治正當性標準其實相當複雜。民從禹而不從舜子丹朱、從禹子啟而不之伯益，皆證實民意民心以為禹及啟賢德，丹朱及伯益不賢；此中民意民心似乎是指標又似乎不是指標。若是

166 《孟子》〈萬章（上）〉：「萬章問曰：『人有言：『至於禹而德衰，不傳於賢而傳於子。』有諸？』孟子曰：『否，不然也。天與賢，則與賢；天與子，則與子。』」李學勤編（註54），頁304。

167 李學勤編（註54），頁304-305。

以賢德為標準，將難以解釋啟之後的家天下；孟子遂說賢與不肖，非人所能為也，天也。至此天命似已處於難測之狀態，究竟是跟著民意、賢肖還是血緣走，其實沒有定則，又好像唯能於統一天下的歷史事實形成後，才能知道天命所歸。其實還是由事實（抑是政治實力？）決定。至此好像並未改變〈洪範〉的論述邏輯。當然，天命依德移轉後跟著血緣走，是自夏而商的通例，天命依德而轉向周室之後，仍然由血緣傳遞，直到下次天命再依革命所顯示的民意而移轉，似乎也就理所當然，無需多作解釋了。

然則孟子只能依靠歷史發展結果，用天命解釋夏禹之子啟繼承而成就了家天下，卻已在無意間問答對話之中，以天命說為家天下背書，而未能真正回答如何擇賢舉能而非依賴血緣關係產生領袖的制度設計問題。「天與賢則與賢，天與子則與子」的說法，一旦為血緣封建背書，其實會混淆也會抵消權力正當性標準在德（或是在民意）的作用。這可能正是學生萬章詢問孟子的原因。

〈洪範〉解釋天命所賦予的統治正當性，其實有多重標準。其中包括一、先王禹之法，二、得天下的事實，三、賢德風範，四、民心歸趨，五、血緣關係，還有六、天子傳位的意志。後二者是〈洪範〉所未明文觸及，但若加深究，就會出現萬章與孟子進行討論時所不能避免的質疑。模糊的天命天意天心會加深宗教性的神學神秘色彩；有助於認證賢德或不肖，也有助於解釋取得天下之事實原因的，則是民意民心。

從〈洪範〉所欲解釋之周武代商的歷史事實發生，直到清末革命出現而轉為民國之際，猶可見清帝退位詔書使用「人心所向，天命可知」字樣描述政權轉移背後的天命哲學說理邏輯¹⁶⁸，當初周人的口吻似乎重現，然則此時已將是民意指引天心走向共和，而非以

168 參見夏新華、胡旭晟整理（註59），頁147-149。

一人一家一姓履踐天命（帝祚）之局面。一旦制定民主憲法，確立了主權在民而不是托天之幸的政府（過去的君），人民的同意，而非天命，才是政治正當性的最終來源，典範即要發生重大的轉移¹⁶⁹。從天命到民意的典範轉移，可以看出三項變化，一是統治者的道德風範不再是天命移轉的指標因素；二是民意取代天意成為最後的政治正當性基礎與標準，三是庶民的政治參與因此成為不可或缺的政治結構性要素¹⁷⁰，而非可有可無、聽由君王裁量的決策商量對象。第二點正是所以證立第三點的原因，經由民主程序制定的憲法明白規定，由民意取代天命成為權力正當性的來源，意義重大。第一，民意不再只是天與天子之間關係的介質，而是經由憲法明文確認，執政者權力正當性之唯一而終極的來源。第二，統治者權威的神秘來源消失，從此主權在民，真正的統治者是人民，不是君王也不是朋黨，政府與人民間也要開始翻轉上下關係，公僕的觀念遂告問世¹⁷¹。第三，民意一旦成為正當性的唯一來源，就必須要有具體驗證民意的程序機制，選舉投票制度也將應運而生。

169 我國憲法第2條：「中華民國之主權屬於全體國民。」即為主權在民原則，亦經司法院大法官釋字第499號解釋指明為修憲的另一界限所在。論者亦有主張周公的民本政治哲學不是主權在君而是主權在天，然則民為天本，實質上即為「主權在民」者，黃玉順，「民本」的人民主權實質及其正義原則，收於：林慶彰、錢宗武、蔣秋華編，第二屆國際《尚書》學學術研討會論文集，頁568（2014年）。

170 憲法規定運用定期選舉制度反映民意、保障人人有言論、集會結社、選舉罷免創制複決以及應考試服公職權等政治平等參與的基本權利，都使得庶民的政治參與成為不可或缺的政治結構性要素。

171 執政的公職人員是公僕，是清末以來常用的辭彙。但政府官員應為庶民服務的思想源頭，於（唐）柳宗元所撰之〈送薛存義之任序〉文中已然見之：「凡吏於土者，若知其職乎？蓋民之役，非以役民而已也。凡民之食於土者，出其什一傭乎吏，使司平於我也。今我受其值，怠其事者，天下皆然。豈惟怠之，又從而盜之。向使傭一夫於家，受若值，怠若事，又盜若貨器，則必甚怒而黜罰之矣。以今天下多類此，而民莫敢肆其怒與黜罰者，何哉？勢不同也。勢不同而理同，如吾民何？有違於理者，得不恐而畏乎！」送薛存義序，中華古詩文古書籍網，https://www.arteducation.com.tw/shiwenv_14beeadaa801.html（最後瀏覽日：2018年12月31日）。此則不僅於吏為然，公職人員自元首以降，何可例外？

其實即使是二次世界大戰之後寫成的世界人權宣言 (Universal Declaration of Human Rights)，也是在中華民國代表張彭春的建議下，於首條中避免使用上帝 (god) 或自然 (nature) 之字眼¹⁷²，而僅訴諸人類平等自由的道理。

二、從等之到政治平等

由一人一家一姓的統治型態所履踐，但其政治正當性判斷標準並不一致的天命哲學，朝向民主憲政以民意作為政治正當性之終極判斷標準過渡時，也涉及背後政治基本價值中一個前提命題的轉變，就是平等即將成為政治基本價值的一個前提命題。

所謂平等，至少可分為兩個不同的關切面向，一是政治平等，一是經濟平等。對於憲政主義而言，兩者都是不可或缺的討論課題，可以並存而互不否定，世界人權宣言以及據之而締結的聯合國兩項國際人權公約，聯合國公民及政治權利國際公約（簡稱公政公約）強調政治平等，聯合國經濟社會文化權利國際公約（簡稱經社文公約）則重視經濟平等，而兩者又共同以平等為其基調，足資印證¹⁷³。

172 MARY ANN GLENDON, A WORLD MADE NEW — ELEANOR ROOSEVELT AND THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 146-47 (2001). 1948年12月10日生效的世界人權宣言前文，首句即強調平等：「鑒於對人類家庭所有成員的固有尊嚴及其平等的和不移的權利的承認，乃是世界自由、正義與和平的基礎。」並有「鑒於為使人類不致迫不得已挺而走險對暴政和壓迫進行反叛，有必要使人權受法治的保護」字樣。G.A. Res. 217A, Universal Declaration of Human Rights, UNITED NATIONS (Dec. 10, 1948), <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/> (last visited Oct. 13, 2020).

173 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, New York, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 993, at 3, https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=080000028002b6ed&clang=_en (last visited Oct. 13, 2020); and International Covenant on Civil and Political Rights, New York, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, at 171, https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280004bf5&clang=_en (last visited Oct. 13, 2020).

政治平等，指的是政治人格平等，也與「人皆可以為堯舜」的提法可相對照比較，沒有人生來就該是不可被替代的統治者，也沒有人只能是遭受歧視的次等公民或只能是被統治者的意思。

經濟平等，指的是經濟分配平等，也就是經濟資源的社會分配如何求其平等的意思，此中不可或缺的一個題目是弱勢保護的問題¹⁷⁴。

如前所述，雖然孔孟都曾出現過政治平等的思想發軔，但政治人格平等顯然不是天命哲學的前提認識，從〈洪範〉鼓吹集中王權以為民之父母的提法，即可瞭解。經濟平等，特別是弱勢保障的部分，與天命哲學則並不衝突，〈洪範〉之中「不虐瑯獨」一語已然道破其意。因此經濟平等不是本文的討論主題。

不與政治平等，〈洪範〉為天子、人臣、庶民建極，階級三

174 荀子即以為禮是界定國人之間分配關係的制度。《荀子》〈禮論〉：「禮起於何也？曰：人生而有欲，欲而不得，則不能無求。求而無度量分界，則不能不爭；爭則亂，亂則窮。先王惡其亂也，故制禮義以分之，以養人之欲，給人之求。使欲必不窮乎物，物必不屈於欲。兩者相持而長，是禮之所起也。禮起於何也？曰：人生而有欲，欲而不得，則不能無求。求而無度量分界，則不能不爭；爭則亂，亂則窮。先王惡其亂也，故制禮義以分之，以養人之欲，給人之求。使欲必不窮乎物，物必不屈於欲。兩者相持而長，是禮之所起也。君子既得其養，又好其別。曷謂別？曰：貴賤有等，長幼有差，貧富輕重皆有稱者也。故天子大路越席，所以養體也；側載茅芷，所以養鼻也；前有錯衡，所以養目也；和鸞之聲，步中武象，趨中韶護，所以養耳也；龍旗九旂，所以養信也；寢兕持虎，蛟韞、絲末、彌龍，所以養威也；故大路之馬必信至，教順，然後乘之，所以養安也。孰知夫出死要節之所以養生也！孰知夫出費用之所以養財也！孰知夫恭敬辭讓之所以養安也！孰知夫禮義文理之所以養情也！」楊倞注、王先謙集解（註87），頁321-324。註71中提到孟子為梁惠王開具的義務清單，則是考慮到弱勢保障而描述經濟分配關係的另一種理想。當代憲政主義關於分配平等如何可能或不可能的精采思辯，參見如 John Rawls, *Distributive Justice*, in JUSTICE 73, 73-94 (Alan Ryan ed., 1993); Robert Nozick, *Distributive Justice*, in JUSTICE 95, 95-116 (Alan Ryan ed., 1993); F. A. Hayek, "Social" or *Distributive Justice*, in JUSTICE 117, 117-58 (Alan Ryan ed., 1993).

分，是倡「等之」¹⁷⁵，而非「平等」。建皇極而使得階級身分因血緣關係而世襲，而終身固定在所屬的社會階層之中不得改變，是〈洪範〉「等之」而直接形成的階級不平等。要到憲法典中明文規定「不分階級」「在法律上一律平等」¹⁷⁶，制度上才得真翻轉¹⁷⁷。

從清末到民國，從君主專制到書寫憲法，其實也是對西方「平等」的觀念意識，從認識的全然陌生到顯赫地進入憲法的一段過程¹⁷⁸。此中對於政治社會必須講究經濟平等的基本觀念其實並無爭議，而是在分配的適當辦法上還有偏左偏右的議論與爭執¹⁷⁹。政治平等的接受程度，則似乎仍非毫無保留¹⁸⁰，兩岸在批准公政公約及經社文公約的經驗上有所差異，已足見之¹⁸¹。然則中國曾派遣代表團參與起草並於1948年在世界人權宣言上簽字，畢竟是歷史事

175 等之，即區別等第的意思，不是使之平等也。等，原指類別，次序也，輩也，又階級也。臺灣中華書局辭海編輯委員會（註4），頁3346。如《禮記》〈樂記〉：「禮義立，則貴賤等矣」，孫希旦（註72），頁986。是指依貴賤區分等第的意思。

176 此係我國憲法第7條規定階級平等之用語。

177 憲法中加以不分階級的字樣，是有特別忌諱，法律使用階級以為區別標準的用意之內，稱為「可疑的區別標準」。

178 李念祖（註129），頁280-282。

179 也就是市場經濟、資本主義與計畫經濟、社會主義之間的擺盪選擇。

180 李念祖（註129），頁275-276、281-283。

181 聯合國此兩項人權公約，於1966年均經中華民國簽署，在其前言中均表示係依據世界人權宣言之內容發展而來，亦均於1976年獲得足額的會員國批准加入而生效。2009年，我國立法院亦依法議決且經總統簽署批准，並於同年4月由立法院通過、總統公布公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法，於2011年12月10日施行。隨後並定期發佈國家人權報告。See Ying-jeou Ma, *President Ma Holds Press Conference on the Release of Taiwan's First Human Rights Report*, 30 CHINESE (TAIWAN) Y.B. INT'L L. & AFF. 183, 183-87 (2012). 中華人民共和國係於2001年6月27日完成經社文公約之批准存放手續，但猶未批准公政公約，與美國係於1992年8月9日完成公政公約之批准存放，卻迄未批准經社文公約，適成對比。See International Covenant on Civil and Political Rights, https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280004bf5&clang=_en (last visited Jan. 4, 2019), and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=080000028002b6ed&clang=_en (last visited Jan. 4, 2019).

實¹⁸²。世界人權宣言已具有世界人權憲章之普世性規範地位¹⁸³，與我國憲法完全可以互為發引。至此，憲政主義憲法的基本價值，業告樹立，成就了實質性的平等價值命題之典範轉移。

表現在「一人一票、票票等值」而為民主制度奠基的平等觀念，與用民之父母勉勵君王，但也用父母子女關係來區別君民地位的天命哲學相比，在憲政主義思想中還有另外一重不同之處，值得注意。平等的公民們經由討論取得共識，共同締結一部民主的憲法，用選舉的方式產生執政者。當一位公民同時擁有選舉權與被選舉權的時候，展現的就是平等參政，也就是說統治者與被統治者的身分，從此可以互換而相互平等的意思。再加上主權在民、人民才是真正的統治者的道理，民選的政府與其公職人員必須向人民負責，政府人員，即使是元首，也只該是為民服務的公僕，不再是高高在上的民之父母，也不能是身分關係不可逆的民之父母。

其實，雖然「人生而平等」作為西方的自明之理，乃是出自18世紀美國開國先賢Thomas Jefferson起草的獨立宣言¹⁸⁴，但即使是在美國，以最能實現個人自由著稱之首部成文憲法，也未能阻擋非洲後裔遭到奴役的不平等待遇¹⁸⁵；甚至於19世紀中進行內戰與修憲，始行廢除奴隸制度¹⁸⁶。之後又維持了近九十年的種族隔離，才

182 世界人權宣言係由1946年6月成立的聯合國人權委員會（其成員包括安理會5國，由美國羅斯福總統夫人（Eleanor Roosevelt）擔任主席，中華民國首席代表張彭春擔任副主席）於1947年元月於紐約舉行之首次會議所催生，宣言於1948年12月10日由聯合國大會逐條投票通過，當日在大會中致詞的張彭春被稱作使得宣言成為可能的四大功臣之一。GLEDON, *supra* note 172, at xx-xxi, 32-33, 166, 169.

183 居功厥偉的羅斯福總統夫人將之稱為人類的國際大憲章（international Magna Carta of all men everywhere）。GLEDON, *supra* note 172, at 166.

184 其經過，see PETERSON ED., *supra* note 133, at xv-xix.

185 其經過，參見如CATHERINE D. BOWEN, MIRACLE AT PHILADELPHIA: THE STORY OF THE CONSTITUTIONAL CONVENTION, MAY TO SEPTEMBER 1787, at 200-04 (1986).

186 Dred Scott v. Sandford, 60 U.S. 393 (1857) 一案判決之後，於1860年代中進行4年內戰後，通過美國憲法增修條文第13條禁止蓄奴。第14條正當法律程序條

經聯邦最高法院判決種族隔離違反憲法¹⁸⁷，至是種族「平等」的典範轉移，其相關運作機制才粗稱完備。到了1970年代美國學者John Rawls的皇皇巨作A THEORY OF JUSTICE¹⁸⁸問世之際，世人始覺恍然，他提出「能讓社會上每位成員都感公平而樂意接受公平原則為何？」的大哉一問，竟是在傳達「人若不平等則難有自由」的人權理念，憲政主義從「自由先於平等」朝向「平等先於自由」的典範移轉，已然上路¹⁸⁹。事實上，1948年12月10日通過的世界人權宣言，才是第一份以平等權開篇並列為人權清單首條的國際憲章¹⁹⁰；也將平等權列為人權清單首條的中華民國憲法，則在一年之前生效施行¹⁹¹。就像出自西方的共產主義即將席捲中國一樣，憲政主義的典範移轉，當時東方西方其實也是正在同步醞釀發生之中。

三、從道義到法治程序

前文言及，彰顯天命的〈洪範〉已具有賦予正當性與加施制裁的法規範芻形，但是〈洪範〉尚不足以構成完足的法規範。〈洪範〉建立的是政治道德規範，期待得到天命的天子能夠樹立最基本

款，成為20世紀平等保障的泉源。See PAUL FINKELMAN, DRED SCOTT V. SANDFORD: A BRIEF HISTORY WITH DOCUMENTS 4 (1997).

187 美國聯邦最高法院於1896年做成Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537(1896)一案，不承認隔離但平等的種族隔離社會法制並不違憲，至1954年 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954)一案，聯邦最高法院改變前案見解，以為種族隔離即是違憲。此案之歷史背景及涉及之社會因素，see ROBERT J. COTTELL ET AL., BROWN V. BOARD OF EDUCATION (2003).

188 See JOHN RAWLS, A THEORY OF JUSTICE (1971)，關於Rawls之公平正義理論與憲政主義及憲法關係，參見如Frank I. Michaelman, *Rawls on Constitutionalism and Constitutional Law*, in THE CAMBRIDGE COMPANION TO RAWLS 394, 394-425 (Samuel Freeman ed., 2003).

189 朱敬一、李念祖，基本人權，頁380-381（2003年）。

190 世界人權宣言序言，「鑒於對人類家庭所有成員的固有尊嚴及其平等的和不移的權利的承認，乃是世界自由、正義與和平的基礎。」第1條：「人人生而自由，在尊嚴和權利上一律平等。」

191 我國憲法係於1946年12月25日國民大會制定，1947年1月1日國民政府公告，同年12月25日施行。

的準則，建立和平的人倫社會秩序，像是父母一樣的謀求庶民的福祉，提出的標準甚高，孔子曾以為非虞舜不能為民之父母，孟子則說五百年必有王者興，雖然猶存樂觀，但已見其難無以復加，乃只能委諸天命而聽之。〈洪範〉盡人事的辦法，則是教導君王了解必備的基礎知識領域，設置善政目標與要項課題，抬高領導地位與集中力量、團結人心的要徑，領導統御的訣竅，解決難題的分法，自我稽核的習慣、行賞行罰之道，甚至暗示不好自為之的後果等等，也因此成為歷代君王經筵學習的基本教材，明太祖有親自箋注〈洪範〉的紀錄¹⁹²，清康熙時則尚編有日講經筵之教材《日講書經解義》¹⁹³。天命是上天所付與君王的道德使命，與其以為〈洪範〉就是一種符合當代意義的法規範，不如看做是對君王對庶民負有政治道德義務（簡稱「道義」）的耳提面命。以〈洪範〉做為君王教育的教材，鼓舞君王極權若與警惕君王不得濫權的效果相較，究竟孰愈？用集中權力的辦法避免政治動亂，會不會反因權力因集中、過大而形成動亂的肇因？恐不能一概而論，也不容樂觀。

憲政主義的憲法典，亦是以政治道義（平等保障每個人的基本權利）為基礎，卻增加了如何實施且有強制作用（政府不依之而為則失去政治正當性）的具體程序機制，包括民主選舉、定期改選、權力分立，乃至於權力分立之中的審判獨立與司法審查。憲政主義的憲法典是法規範，但與法家強調刑罰¹⁹⁴而與儒家禮治構成互補的

192 連文萍，明代皇族的《尚書》講習，收於：林慶彰、錢宗武編，首屆國際《尚書》學學術研討會論文集，頁223（2012年）。

193 何銘鴻，《日講書經解義》之帝王教化觀探析，收於：林慶彰、錢宗武編，首屆國際《尚書》學學術研討會論文集，頁233（2012年）。

194 《漢書》〈藝文志〉：「法家者流，蓋出於理官，信賞必罰，以輔禮制。易曰：『先王以明罰飭法。』此其所長也。及刻者為之，則無教化，去仁愛，專任刑法，而欲以致治；至於殘害至親，傷恩薄厚。」班固撰、顏師古注（註129），頁446；《史記》〈申不害韓非列傳〉：「申子之學本於黃老而主刑名。」「韓非者，韓之諸公子也。喜刑名法術之學，而其歸本於黃老。」司馬遷（註2），頁755。統治者如法家所言而尚刑，是華文世界中觀念上常將法與刑畫上等號而難知其區別的重要歷史原因。

出禮入刑¹⁹⁵，卻又刑不上大夫¹⁹⁶，也少制度化的辦法使君王去位相較，頗不相同。憲法典的辦法不是懲之以刑，也非「藉法專制」(to rule by law)，而是「法律主治」(簡稱法治)(the rule of law)¹⁹⁷。

法治的辦法，是用憲法取代了君王位於國家權力頂端的絕對位置¹⁹⁸。成文憲法其有Joseph Raz指出法律制度獨具的制度重要性：它是制度，指導行為，解決爭端，擁有最高的權威介入一切受規範的行為¹⁹⁹。成文憲法既如自然法一般地是實證法所不能違逆的較高法，又已化身為實證法條進入實證法體系，「披著實證法的甲冑，卻有著自然法的靈魂」²⁰⁰。使得國家元首以降的政府人員，和庶民一樣需要守法。不直接訴諸刑罰的制裁，也自有辦法應付不遵守憲法的政府人員，包括國家元首在內，使之就範。兩相對照之下，足以令人恍然，於憲法典在西方問世之前，因為天子已處於〈洪範〉

195 陳寵曰：「禮之所去，刑之所取，失禮則入刑。」范曄撰、李賢等注，後漢書，陳寵傳，頁411（1997年）。又《禮記》〈王制〉：「凡制五刑，必即天論。郵罰麗於事。凡聽五刑之訟，必原父子之親、立君臣之義以權之。」孫希旦（註72），頁371。於此已可證瞿同祖以為，傳統法律建立「是非，毋寧是繫於身分的。」「從家法與國法，家族秩序與社會秩序的連繫中，我們可以說家族實為政治法律的單位，政治法律組織只是這些單位的組合而已。這是家族本位政治法律的理論的基礎」的道理所在。瞿同祖，中國法律與中國社會，頁15、25（1984年）。

196 《禮記》〈曲禮〉：「國君撫式，大夫下之。大夫撫式，士下之。禮不下庶人，刑不上大夫。刑人不在君側。」孫希旦（註72），頁81-82。

197 rule of law，蘇俊雄譯為「法律支配」，蘇俊雄，法治政治，頁12（1990年）；劉慶瑞譯為「法治政治」，並且指出憲政主義就是法治政治。劉慶瑞（註7），頁1。於雷賓南所譯、英哲Albert V. Dicey所著INTRODUCTION TO THE STUDY OF THE LAW OF THE CONSTITUTION《英憲精義》書中則譯為「法律主治」；書中言及法律主治為英憲之主要特性，可分三點言之。一是武斷的權力不存在；二是法律之前人人平等，官民皆然；三是憲法的一般法則，係由普通法院就涉及人民權利訴訟案件之判決累積形成。其大意與本文所述之法治之意相通。Albert V. Dicey著，雷賓南譯（註68），頁273-280、284-285。「to rule by law」與「the rule of law」的差異，參見如TAMANAH, *supra* note 84, at 92-93.

198 CORWIN, *supra* note 142, at 1.

199 RAZ, *supra* note 62, at 121.

200 朱敬一、李念祖（註189），頁379。

所推崇的權力頂端絕對位置，中土乃少憲政思想發展之餘地，雖然如前所述，憲政思想與儒家思想確實具有不少重疊之處²⁰¹。

基於民主原則寫成，以法治取代人治的成文憲法典，會依權力分立原則規定政府如何組成，各部門都有不能做的或必須做的事，須要遵守。除了法官可享終身在位的待遇以確保個案可以得到獨立審判之外²⁰²，政府人員，包括經由普選投票產生的國家元首在內，都有定期改選或依法免去職務而由他人繼任的制度性安排²⁰³。

另一個有效控制政府行為的程序設計是，憲法明文規定政府的法律或是命令違反憲法時，由司法部門循司法程序確認其無效²⁰⁴。這就提供了一種機會，用公平合理的方法來質疑政府人員濫用權力，而且否定濫用權力的決定具有拘束力。能夠褫奪政府違憲舉措的公共信用與支配作用，就足以防免政府濫用權力。憲法控制權力的功能，不但展現在日常司法審查用解釋憲法的方式控制政府的違憲施政，即使遇到誤用修憲權力時也不例外時²⁰⁵，就更加證明了相關程序機制的高度可行性。

憲政主義憲法講究基本權利的保障，其實是要藉重權力分立與司法審查有效的運作，使得每一個個人面臨國家權力機器臨身的場合，其最基本而應受平等尊重的個人福祉，都有機會在公平而且合乎理性的司法程序之中，由於獨立的司法敢於不對政府權力唯唯諾

201 此一主題之詳細討論，特別是關於建立政治秩序規範、政權的正當性、神權衰退、人道思想與制約權力等節，參見李念祖（註164），頁102-157。

202 我國憲法第81條與司法院大法官釋字第13號解釋參照，司法院秘書處，司法院大法官會議解釋彙編，5版，頁34-35（1991年）。

203 例如我國憲法增修條文第2條第6、8項。

204 例如我國憲法第171、172條參照。

205 我國司法院大法官應請求而運用憲法解釋（司法院釋字第499號解釋）宣告一次修憲因違反修憲之憲法界限而違憲，卒至撥亂反正，具見司法程序運作可以發揮之憲政作用。其經過，參見李念祖，案例憲法I——憲法原理與基本人權概論，2版，頁75-77、91（2007年）。

諾，而能得到救濟。法治的理想，就憲政主義的憲法而言，其實是藉著權力機關的相互制衡，而終可在司法的殿堂之中，讓每一個個人的福祉都能平等地獲得確保。保障權利與維持秩序是法秩序之中向度不同的兩種功能。憲政主義的政府（行政部門）固也會為了維持秩序而追訴犯罪，但司法審判為了保障以人格平等為前提的基本權利，就會要求政府用合乎公平正義的手段追訴犯罪，像是「疑罪從無」²⁰⁶就是為了保障基本權利而運作的重要原則。如果不是為了保障基本權利而只是為了維持秩序，其實審判獨立的需要並不明顯。然而如果是為了保障權利，審判獨立可就十分重要了。審判獨立，說的原就是由法官而非君主操持審判獄訟的權力。制度上要將保障權利看成是司法審判的核心功能時，始有基本權利保障之可言。獨立審判的法院另一個重要之處在於，作為憲法所設計執行並實現憲法規範的機關（institution），法院有義務也有權力針對憲法所規範的對象，包括國家元首在內的公職人員，通用憲法規範並加以拘束²⁰⁷。這是天命哲學支撐〈洪範〉以樹立的皇權所不具備的制度化程序機制。

定期選舉促成政治權力的和平移轉，加上憲法有效可行的政府違憲行為控制程序（權力分立與司法審查），使得依賴革命挑戰惡君的流血，與五百年必有王者興的不確定等待，都會成為多餘。有王者風範的政治家出現，固然可以政治清明，但即使長期缺乏王者政治家，即使執政者不知尊崇統治道義，也有對應辦法；以獨立的司法形成終局的裁判解決爭端，乃能大幅減少過度濫權而招致政治動亂的危險，有了憲法較有機會跳出梁漱溟先生所說一治一亂的歷

206 當代亦稱為推定無罪原則。儒家經典中之慎刑思想，亦有疑罪從無的古典論述，所以彰顯君主的仁德也。如《禮記》〈王制〉：「疑獄，汎與眾共之；眾疑，赦之。必察小大之比以成之。」孫希旦（註72），頁371。

207 這正是法規範所必須具有的主要運作機制，如法院所必須具備的功能。RAZ, *supra* note 62, at 109-10. 我國司法院大法官釋字第419、627號解釋，其接拘束國家元首，已具備此一重要特徵。

史循環²⁰⁸，使之不再發生；反而更能接近〈洪範〉所憧憬彝倫攸敘，至臻隆治的境界。對國家元首而言，憲法不是君王集權的教材，而是司法程序中可以加施拘束，不許成為獨夫的規範。有別於人治依賴道義，法治構成天命哲學走向憲政主義極其重要的典範轉移。

憲法背後的憲政主義，以其民主正當性轉變〈洪範〉背後的天命哲學，用一人一票、票票平等的多數決體制取代為民父母的天子予一人，乃是奠基於權力有惡的假設²⁰⁹。以美國聯邦成文憲法典為例，一方面推崇民主多數決的政治正當性，另一方面也深懷戒心，載具多項抑制民主多數之惡的制度設計。其一就是以共和主義的代議政治取代直接民權的運作²¹⁰。二是利用權力分立機制，使多數選出的立法權（國會）與多數選出的行政權（總統）相為抗衡，甚至以兩院制的國會相互牽制²¹¹。三是以司法審判理性防範依多數而決的立法及行政部門冒犯憲法保障的個人基本權利；此中與其說是不民主與民主的對抗²¹²，毋寧以為是憲法為了防止立法的多數侵犯身為少數的個人基本權利而設計的權力限制；正與人民公審不是民主制度所能接受的審判方式，道理相通²¹³。即使是多數決民主，權力

208 梁漱溟（註104），頁226-227。

209 前引的聯邦論中說到政府是人類本性的反映，人如果是天使即不需要政府，即是在說民主政府也有以權力為惡的問題存在。

210 論者有謂聯邦論「書中以所謂的『共和制』取代『民主制』」，「這兩種制度的差異，在於共和制以民選產生公職人員主掌政府，而民主制則與人民主掌政府，換言之，前者是間接民主，在人民與政府權力之間有『代表』作為中介，後者則是直接民主」，錢永祥（註105），頁vi-vii。

211 Federalist Papers No. 58; 相關討論，參見Charles A. Beard著，楊日旭譯，共和國，頁260（1981年）。

212 論者有將非由選舉產生的法官審查國會立法合憲性的機制看成是反多數決的設計者，稱為「反多數的困難」（the Counter-Majoritarian Difficulty）。See ALEXANDER M. BICKEL, THE LEAST DANGEROUS BRANCH — THE SUPREME COURT AT THE BAR OF POLITICS 16-23 (1962).

213 即使如孟子所說「國人皆曰可殺，然後察之，見可殺焉，然後殺之。」乃至《周禮》〈秋官司寇〉：「以三刺斷庶民獄訟之中：一曰訊群臣，二曰訊群吏，三曰訊萬民。聽民之所刺宥，以施上服、下服之刑。」（鄭玄注、賈公彥疏、

有惡的假設並未動搖。

憲政主義的法治，在憲法中不設傳統法家偏愛的刑罰。基本的制裁，不過是使違憲行為無效；最重的制裁，不過是法定任期結束前之去位。皆只是移去憲法已經合法授與的權力地位，或在事後循否定其權力行事的正當性與拘束力而已。憲法如生權威（authority），不仗恃武力的強制，而是藉著可行與有效的程序設計，試圖贏得人們產生Joseph Raz所說對於法的尊重，從而經常自願服膺（voluntary compliance）²¹⁴，促成民主憲政「彝倫攸敝」，長期普遍實現基本權利。畢竟在現實的政治秩序環境之中，自願服膺而非強施制裁，才是自由民主憲政發揮實效的主要原因。

憲政主義用分權與司法理性防制民主多數濫用權力的危險，也正是確保典範完成有效轉移的辦法。憲法者，無刑之法，人國之禮也。

陸、結語

古代的君民關係（今日應該稱為人國關係），就像師生關係一樣，雖然不在五倫之中，也常被認為可以類比為倫理關係的一種價值關係；一旦與宗親血緣相連結，自然更成為一種人倫價值關係。出自西方的憲政主義，就是在界定人國之間應該具有何種價值關係。作者身體心諳中華傳統文化之裏髓，亦心儀源出西方之憲政主義思想及其文化，尚有足以充實數千年道德傳統與政治文化的不備

阮元等撰（註97），頁7。）所載，也與受到權力操弄的人民公審有間。

214 “Voluntary compliance is essential to the rule of law.”（自願服從乃是法律主治之實質要素。）Archibald Cox, *Direct Action, Civil Disobedience, and the Constitution*, in CIVIL RIGHTS, THE CONSTITUTION, AND THE COURT 2-18 (Archibald Cox et al. eds., 1967).

之處。乃有本文之作。

憲法一詞，今日華文世界已不陌生，畢竟是來自翻譯用語，而非由中土文化中自然生成。《尚書》〈洪範〉一篇使用的洪範二字，字面語意恰正是憲法的同義詞；然則〈洪範〉背後的政治文化基底，是周初以來「天命靡常，惟德是輔」的天命哲學傳統，與依憲政主義而頒布的憲法典，既有其共通之處，亦有若干重要差異。當滿清一代成為過去，憲政主義之憲法終將為中土世界所採納時，即不免發生典範轉移。

依本文之研究，基於天命哲學觀所生的〈洪範〉，與憲政主義的憲法，在（一）認知權力有惡，乃須建立賦予統治正當性的標準，而且言說制裁的規範、（二）以庶民福祉為施政之目的性價值、（三）追求樹立和平穩定的政治秩序、（四）在朋黨政治之上建立公正無偏的基準，與（五）庶民參與形成決策的審議民主發源，皆有其共通性。

洪範與憲法典之間，在（一）凡君王皆濫權的假設、（二）政治人格平等的假設、（三）定期選舉領袖的機制、（四）開明專制不是權力分立等四個方面，仍有明顯的政治文化觀念差異。後二者都與天命哲學在強調政治道義的實質價值甚於重視防止權力為惡的程序性設計，以致不易有效處理君王為惡引起循環政治動亂革命流血的歷史難題，可資對照。

比較〈洪範〉與憲法典，背後涉及的典範轉移有三處，一是在政治正當性的基礎上要從「天命」完全轉變為主權在民的「民意」；二是在前提價值上從樹立政治階級的「等之」轉變為政治平等的「平等」；三是在方法上於強調政治「道義」之外，增加法治的「程序」，包括權力分立與獨立司法審查的設計，用具備檢驗政治正當性功能的和平正當程序來維持政治正當性，才更有機會有效解決天命哲學遺留的歷史難題。

參考文獻

1. 中文部分

- Albert V. Dicey著，雷賓南譯（1991），英憲精義，臺北：帕米爾書店。[Dicey, Albert V. 1855. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan and Co., Ltd.]
- Bodde, Derk, and Clarence Morris著，朱勇譯（2008），中華帝國的法律，南京：江蘇人民出版社。[Bodde, Derk, and Clarence Morris, 1976. *Law in Imperial China*. Cambridge, MA: Harvard University Press.]
- Charles A. Beard著，楊日旭譯（1981），共和國，臺北：國民大會憲政研討會。[Beard, Charles A. 1943. *The Republic*. New York, NY: Viking Adult.]
- Edward Jenks著，嚴復譯（2009），社會通詮，臺北：臺灣商務。[Jenks, Edward. 1900. *A History of Politics*. Boston, MA: Dutton.]
- 于省吾（1985），尚書新證，臺北：崧高書社。
- 左丘明著，竹添光鴻箋（2005），左傳會箋（上冊），臺北：天工書局。
- （2005），左傳會箋（下冊），臺北：天工書局。
- 司法院秘書處（1991），司法院大法官會議解釋彙編，5版，臺北：司法院。
- （2000），司法院大法官會議解釋續編（十三），臺北：司法院。
- 司馬遷（2010），史記，2版，臺北：臺灣商務。
- 朱永嘉、蕭木（1995），新譯呂氏春秋（上冊），臺北：三民。
- （1995），新譯呂氏春秋（下冊），臺北：三民。
- 朱建民原譯，陳沖、張桐銳增譯（2014），德意志聯邦共和國基本

- 法譯文，收於：司法院大法官書記處編，德國聯邦憲法法院裁判選輯（十五），頁337-394，臺北：司法院。
- 朱敬一、李念祖（2003），基本人權，臺北：時報文化。
- 朱熹集注、陳戍國標點（2004），四書集注，長沙：岳麓書社。
- 余英時（2003），序，收於：朱敬一、李念祖合著，基本人權，頁14-15，臺北：時報文化。
- （2010），中國文化史通譯，New York, NY: Oxford University Press。
- 何銘鴻（2012），《日講書經解義》之帝王教化觀探析，收於：林慶彰、錢宗武編，首屆國際《尚書》學學術研討會論文集，頁231-248，臺北：萬卷樓。
- （2014），王安石〈洪範傳〉之解經形式，收於：林慶彰、錢宗武、蔣秋華編，第二屆國際《尚書》學學術研討會論文集，頁223-238，臺北：萬卷樓。
- 吳庚（1998），基本權的三重性質——兼論大法官關於基本權解釋理論體系，收於：司法院編，司法院大法官釋憲五十週年紀念論文集，頁1-52，臺北：司法院。
- 李民、王健（2000），尚書譯注，上海：上海古籍出版社。
- 李念祖（2007），案例憲法I——憲法原理與基本人權概論，2版，臺北：三民。
- （2010），「民之父母」與「始作俑者」之先秦儒家憲政思想端緒論稿，收於：吳庚教授七秩華誕祝壽論文集編輯委員會編，政治思潮與國家法學——吳庚教授七秩華誕祝壽論文集，頁74-76，臺北：元照。
- （2012），「民之父母」，「其無後乎」？——論先秦儒家古典憲政思想的進度與限度，收於：人國之禮——憲法變遷的跨越，頁99-186。
- （2012），「民之父母」與先秦儒家古典憲政思想初探——從上博楚竹書簡文談起，收於：人國之禮——憲法變遷的跨越，

頁9-55，臺北：三民。

—— (2012)，人國之禮——憲法變遷的跨越，臺北：三民。

—— (2013)，從陌生到顯赫——平等條款入憲史談片，法制史研究，24期，頁264-287。

—— (2013)，審判獨立、司法獨立、檢察獨立、檢察中立之憲法釋義辨，收於：司法者的憲法（二），頁407-428，臺北：元照。

李俊（1989），中國宰相制度，臺北：臺灣商務。

李學勤編（1999），尚書正義，北京：北京大學出版社。

—— (2001)，孟子注疏，臺北：台灣古籍出版社。

杜勇（2018），清華簡與古代探賾，北京：科學出版社。

那思陸（2004），中國審判制度史，臺北：正典。

孟德斯鳩著，嚴復譯（2010），孟德斯鳩法意，臺北：臺灣商務。

屈萬里（1983），尚書集釋，臺北：聯經。

—— (1983)，詩經詮釋，臺北：聯經。

法治斌、董保城（2003），憲法新論，臺北：自版。

易建平（2004），部落聯盟與酋邦——民主、專制、國家：起源問題比較研究，北京：社會科學文獻出版社。

范曄撰、李賢等注（1997），後漢書，陳寵傳，頁410-415，北京：中華書局。

徐世虹（2010），沈家本全集，北京：中國政法大學出版社。

孫希旦（1990），禮記集解，臺北：文史哲出版社。

夏新華、胡旭晟整理（2004），近代中國憲政歷程：史料薈萃，北京：中國政法大學出版社。

班固撰、顏師古注（1997），漢書，北京：中華書局。

殷海光（2010），學術與思想（上冊），臺北：臺大出版中心。

荊門市博物館（2005），郭店楚墓竹簡，北京：文物出版社。

高全喜（2011），立憲時刻——論〈清帝遜位詔書〉，桂林：廣西師範大學出版社。

- 高佑仁（2018），清華伍書類文獻研究，臺北：萬卷樓。
- 馬漢寶（1978），龐德論中華民國憲法之發展，憲政時代，3卷3期，頁29-30。
- 張台麟譯（1996），法蘭西共和國憲法，收於：國民大學秘書處資料組編，新編世界各國憲法大全（第二冊 歐洲非洲國家），頁279，臺北：國民大會秘書處。
- 張君勱（1986），新儒家思想史，臺北：弘文館。
- 梅仲協（1989），法學緒論，2版，臺北：中國文化大學出版部。
- 梁治平（2011），尋求自然秩序中的和諧——中國傳統法律文化研究，臺北：臺大出版中心。
- 梁漱溟（1977），中國文化要義，臺北：問學。
- 連文萍（2012），明代皇族的《尚書》講習，收於：林慶彰、錢宗武編，首屆國際《尚書》學學術研討會論文集，頁209-230，臺北：萬卷樓。
- 郭建勳注譯（2011），新譯尚書讀本，臺北：三民。
- 許倬雲（1990），西周史，3版，臺北：聯經。
- （2006），萬古江河——中國歷史文化的轉折與開展，臺北：漢聲文化。
- 許濱松（1996），英美公務員政治中立之研究——兼論我國公務員政治中立應有之作法，收於：彭錦鵬編，文官體制之比較研究，頁151-171，臺北：中央研究院歐美研究所。
- 陳恆嵩（2012），魏校及其《尚書》經筵講義析論，收於：林慶彰、錢宗武主編，首屆國際《尚書》學學術研討會論文集，頁187-208，臺北：萬卷樓。
- 程元敏（2012），尚書周書——牧誓洪範金縢呂刑篇義證，臺北：萬卷樓。
- 傅佩榮（2018），先秦儒家哲學十六講，臺北：立緒文化。
- 傅斯年（1985），性命古訓辨正，臺北：新文豐。
- （2009），中國古代文學講義，北京：北京大學出版社。

- 傅隸樸(2006), 春秋三傳比義(下冊), 臺北: 臺灣商務。
- 黃玉順(2014), 「民本」的人民主權實質及其正義原則, 收於: 林慶彰、錢宗武、蔣秋華編, 第二屆國際《尚書》學學術研討會論文集, 頁555-578, 臺北: 萬卷樓。
- 黃宗義(1986), 明夷待訪錄, 臺北: 金楓。
- 楊家駱編(1985), 尚書注疏及補正, 3版, 臺北: 世界書局。
- 楊倞注、王先謙集解(2000), 荀子集解、考證, 2版, 臺北: 世界書局。
- 臺灣中華書局辭海編輯委員會(1996), 辭海, 8版, 臺北: 中華書局。
- 劉節(1987), 洪範疏證, 收於: 顧頡剛編, 古史辨(五), 頁388-403, 臺北: 藍燈文化。
- 劉慶瑞(1978), 中華民國憲法要義, 10版, 臺北: 自版。
- 鄭玄注、賈公彥疏、阮元等撰(2009), 周禮注疏及補正, 臺北: 世界書局。
- 黎靖德編(1986), 朱子語類, 卷79, 北京: 中華書局。
- 蕭高彥(2018), 馬基維利主義、國家理性說與暴君放伐論: 思想史的考察與政治哲學的反思, 「吳庚教授逝世週年紀念」學術研討會, 中央研究院法律學研究所、臺灣大學公共事務研究所主辦, 2018年12月15日。
- 錢永祥(2000), 權力與權利的辯證: 《聯邦論》導讀, 收於: 謝淑斐譯, 聯邦論 The Federalist Papers, 頁IV-XIII, 臺北: 貓頭鷹。
- 錢宗武、江灝譯注(1996), 尚書, 臺北: 臺灣古籍出版社。
- 錢穆(1988), 論語新解, 臺北: 東大圖書。
- 戴季陶(1927), 孫文主義之哲學的基礎, 5版, 上海: 自版。
- 謝瑞智譯(1996), 日本國憲法, 收於: 國民大會秘書處資料組編, 新編世界各國憲法大全(第一冊 亞洲國家), 頁217-218, 臺北: 國民大會秘書處。

- (1996)，大不列顛與北愛爾蘭聯合王國（英國）憲法法典，收於：國民大會秘書處資料組編，新編世界各國憲法大全（第二冊 歐洲非洲國家），頁6-7，臺北：國民大會秘書處。
- 瞿同祖（1984），中國法律與中國社會，臺北：里仁書局。
- 蘇俊雄（1990），法治政治，臺北：正中。
- 顧頤剛（1987），論今文尚書著作時代書（1923年6月10日致胡適之書），收於：顧頤剛編，古史辨（一），頁200-207，臺北：藍燈文化。
- 顧頤剛編（1987），討論古史答劉胡二先生，收於：古史辨（一），頁105-150，臺北：藍燈文化。
- 顧寶田注釋（2016），新譯穀梁傳，2版，臺北：三民。

2. 外文部分

- de Bary, William Theodore. 1998. *Asian Value and Human Rights: A Confucian Communitarian Perspective*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Bickel, Alexander M. 1962. *The Least Dangerous Branch — The Supreme Court at the Bar of Politics*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Bowen, Catherine D. 1986. *Miracle at Philadelphia: The Story of the Constitutional Convention, May to September 1787*. New York, NY: Book-of-the-Month Club.
- Chan, Wing-Tsit. 1963. *A Source Book in Chinese Philosophy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Corwin, Edward S. 1976. *The “Higher Law” Background of American Constitutional Law*. 10th ed. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Cottrol, Robert J., Raymond T. Diamond, and Leland B. Ware. 2003. *Brown v. Board of Education*. Lawrence, KS: University Press of Kansas.

- Cox, Archibald. 1967. Direct Action, Civil Disobedience, and the Constitution. Pp. 2-18 in *Civil Rights, the Constitution, and the Court*, edited by Archibald Cox, Mark D. Howe and J.R. Wiggins. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Dershowitz, Alan M. 2004. *Rights from Wrongs: A Secular Theory of the Origins of Rights*. New York, NY: Basic Books.
- Finkelman, Paul. 1997. *Dred Scott v. Sandford: A Brief History with Documents*. Boston, MA: Bedford St. Martin's.
- Glendon, Mary Ann. 2001. *A World Made New — Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights*. New York, NY: Random House.
- Hamilton, A., J. Madison, and J. Jay. 1982. *The Federalist Papers*. New York, NY: Bantam Books.
- Hayek, F. A. 1993. "Social" or Distributive Justice. Pp. 117-158 in *Justice*, edited by Alan Ryan. New York, NY: Oxford University Press.
- Jay, Antony. 2005. *Oxford Dictionary of Political Quotations*. 2d ed. Oxford: Oxford University Press.
- Kymlicka, Will. 2001. *Contemporary Political Theory: An Introduction*. 2d ed. New York, NY: Oxford University Press.
- Ma, Ying-jeou. 2012. President Ma Holds Press Conference on the Release of Taiwan's First Human Rights Report. *Chinese (Taiwan) Yearbook of International Law and Affairs* 30:183-187.
- Michaelman, Frank I. 2003. Rawls on Constitutionalism and Constitutional Law. Pp. 394-425 in *The Cambridge Companion to Rawls*, edited by Samuel Freeman. Cambridge: Cambridge University Press.
- Neely, Sylvia. 2007. *A Concise History of the French Revolution*. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield.

- Nozick, Robert. 1993. Distributive Justice. Pp. 95-116 in *Justice*, edited by Alan Ryan. New York, NY: Oxford University Press.
- Peterson, Merrill D., ed. 1977. *The Portable Thomas Jefferson*. New York, NY: Penguin Books.
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press.
- . 1993. Distributive Justice. Pp. 73-94 in *Justice*, edited by Alan Ryan. New York, NY: Oxford University Press.
- Raz, Joseph. 1979. *The Authority of Law*. Oxford: Clarendon Press.
- . 2019. The Law's Own Virtue. *Oxford Journal of Legal Studies* 39:1-15.
- Tamanaha, Brian Z. 2004. *On the Rule of Law-History, Politics, Theory*. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
- Troper, Michel. 2008. Constitutional Law. Pp. 1-34 in *Introduction to French Law*, edited by George A. Herman and Etienne Picard. New York, NY: Wolters Kluwer.